

רשות ערעור אזרחי 6233 / 02

א

אקסטל בע"מ

נגד

1. קאלמא ווי תעשיה, שיווק אלומיניום זכוכית ופרזול בע"מ
2. צפי פרופיל חן (1983) בע"מ

ב

בבית-המשפט העליון

[4.2.2004]

לפני השופטים י' טירקל, א' פרוקצ'יה, מ' נאור

ג

בין המערערת למשיבות נכרת הסכם הפצה, שבמסגרתו נכללה תניית בוררות. המשיבות ביקשו למנות בורר על-פי ההסכם לאחר שההסכם פקע. המערערת טענה כי ההסכם הינו הסדר כובל ולפיכך בטל, ועמו בטלה גם תניית הבוררות, בית-המשפט המחוזי קבע כי פקיעת ההסכם אינה מבטלת את תניית הבוררות, וכל סכסוך הנוגע לתקופת ההסכם יידון לפיו. מכאן הבקשה לרשות ערעור.

ד

בית-המשפט העליון פסק:

א. (אליבא דשופט י' טירקל):

ה

(1) סעיף 2(א) לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 (להלן – החוק) מגדיר הסדר כהסדר כובל אם הוא מונע תחרות בעסקים או מפחיתה. בצדו מונה סעיף 2(ב) לחוק רשימה של עניינים המקימים חזקה של פגיעה בתחרות (1988).

ו

(2) מקובל להבחין בין הסדר "אופקי" – הסדר בין גופים מתחרים – לבין הסדר "אנכי" – הסדר בין יצרן לבין משווק או מפיץ. כבילה במסגרת הסדר "אופקי" שונה בהשפעתה על התחרות מכבילה במסגרת הסדר "אנכי", ופגיעתה בתחרות חמורה מפגיעתה בתחרות של כבילה במסגרת הסדר "אנכי". לפיכך אין להתייחס לכבילה במסגרת הסדר "אופקי" ולכבילה במסגרת הסדר "אנכי" כמיקשה אחת (1988).

ז

(3) הרחבת תחומי פריסתו של סעיף 2 לחוק אינה רצויה, וראוי לנקוט פרשנות מצמצמת של הוראות החוק הבאות להגדיר הסדר כהסדר כובל, בין היתר מהטעמים האלה: האחד, צמצום התוצאות שיש לקביעה שהסדר הוא הסדר כובל בתחום המשפט הפלילי; השני, ייחוס משקל גדול יותר לערכים של תום-לב, הגינות ויושר בהשוואה למשקלה של ההגנה על התחרות החופשית; השלישי, צמצום הפגיעה בוודאות המשפטית על-ידי הפחתת מספר המקרים של ביטול חוזה בשל אי-חוקיות שגורמת הגדרתו כהסדר כובל. לכך ניתן להוסיף טעם נוסף והוא הצורך להימנע מהגבלת

פעילות עסקית מקובלת ורווחת שנועדה להשיג מטרות כלכליות ועסקיות ראויות (647 – ז).

(4) שני סוגי כבילות שעניינן מחיר הבאים בגדר סעיף 2(ב)(1) לחוק, זכו לעיון בפסיקה ובספרות: האחד, תיאום מחיר במסגרת הסדר "אופקי" – כאשר גופים מתחרים קובעים ומתאמים ביניהם את המחיר; השני, קביעת מחיר במסגרת הסדר "אנכי" – כאשר יצרן קובע ומכתיב מחיר למשווק או למפיץ. הסדרים "אנכיים" שבהם יצרן מתחייב כלפי מפיץ או רוכש אחר למכור לו את מוצריו במחירים הנמוכים ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהוא מוכר (Most Favored Nation), נדונו בבתי-משפט בארצות-הברית ולא נפסלו. נאמר כי הסדר כזה כשלעצמו אינו בהכרח הסדר כובל, אלא יש לבחון אותו לפי סבירותו. הסכמים אנכיים מסוג Most Favored Nation מקובלים ורווחים בארצות-הברית וכנראה גם בישראל. יש לצמצם אפוא ככל האפשר את הגדרתם הגורפת יתר על המידה של הסכמים כאלה כהסדרים כובלים (648 ב, ה, 649).

(5) חלוקת שוק לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק מתקיימת כאשר בני-אדם המנהלים עסקים מחלקים ביניהם את השוק באופן שפעילותו של כל אחד מהעסקים מוגבלת לחלק מן השוק. הסכמי בלעדיות בטריטוריה מסוימת הם סוג של חלוקת שוק, וההבחנה בין הסכמים אופקיים להסכמים אנכיים קיימת גם בהסכמי בלעדיות כאלה. חלוקת שוק, על-ידי הענקת זכויות של בלעדיות המתייחסות לסוג מסוים של צרכנים היא אסורה כשלעצמה, אולם חלוקת שוק על-ידי הענקת זכויות של בלעדיות המתייחסות למיקום הגאוגרפי של המפיצים אינה אסורה כשלעצמה, אלא יש לבחון אותה בכל מקרה ומקרה לפי מבחן הסבירות (650 – ו, 651 ב).

ב. אפילו בא ההסכם בגדר הסדר כובל הבטל מחמת אי-חוקיותו, אין בכך בהכרח כדי לבטל גם את תניית הבוררות. יודגש כי אי-החוקיות הגלומה בהסדר כובל אינה אי-חוקיות בוטה המטמאת כל מה שהיא נוגעת בו, אלא היא אי-חוקיות "מתונה" במובן זה שאינה מביאה בהכרח לבטלות ההסכם, אשר הממונה על ההגבלים העסקיים רשאי להכשירו. יתר-על-כן, אפילו חלק מן ההסכם בטל מחמת אי-חוקיות ניתן להפריד בין החלק הפסול לחלק הכשר, ואפילו לא ניתן להפריד בין חלקי ההסכם ניתן "להחיותו", בשלמותו או בחלקו. הלכה היא כי פקיעתו של חוזה אינה מפקיעה מאליה גם את סעיף הבוררות שבו, אלא יש לבחון כיצד ומדוע פקע החוזה (652 ג – ז).

ג. (דעת מיעוט – השופטת מ' נאור):

(1) בהלכה שנקבעה לא מכבר בבית-המשפט העליון בדבר פרשנותו של סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים, נקבע כי החזקות המפורטות בסעיף 2(ב) לחוק הן חזקות חלוטות. בהתקיים אחת מהחזקות החלוטות אין צורך להוכיח שהייתה בפועל פגיעה בתחרות כדי שייקבע קיומו של הסדר כובל (657 – ז).

(2) סעיף 2 לחוק אינו מבחין בין הסדרים אופקיים להסדרים אנכיים. לא ניתן להכניס את ההבחנה המוצעת, השונה מהדין המצוי, בדרך של פרשנות. להבחנה זו אין עיגון בלשונו של החוק (658 – ז, 659 ג).

ד. (דעת מיעוט – השופטת מ' נאור):

א (1) במקרה דנן לא היה מקום למינוי בורר. שני טעמים לדבר, ודי בכל אחד מהם בנפרד כדי להביא למסקנה האמורה: הטעם האחד הוא שבשאלה נושא הבוררות תלוי ועומד הליך בבית-המשפט; הטעם השני נעוץ בכך שבלב המחלוקת עומד הסדר כובל (663ב – ג).

ב (2) הסדר כובל (שלא זכה לאישור של בית-הדין להגבלים עסקיים) לא רק משפיע על הצדדים לו אלא גם פוגע בתחרות בשוק, כלומר בציבור כולו – בצרכני המוצר ובמתחרים פוטנציאליים חדשים שהיו עשויים להיכנס לשוק אלמלא ההסדר הכובל. אין זה ראוי שהסדר כובל (שהוא גם עבירה פלילית) יידון בבוררות. קביעת סעיף בוררות בהסכמים שבלבם הסדר כובל עשויה לטאטא הסדרים שכאלה הצדה, הרחק מהעין הציבורית הבוחנת (664ג – ד).

ג (3) חוזה בלתי חוקי אינו יכול לשמש נושא להסכם בין צדדים, ועל-כן אינו יכול להיות העניין של בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968. כדי שיהיה ניתן להעביר עניין לבוררות, הסכם הבוררות עצמו צריך להיות חוקי, ובנוסף נושא הבוררות צריך להיות עניין שניתן להעבירו לבוררות, כלומר נושא הבוררות, כמו הסכם הבוררות עצמו, אינו יכול להיות בלתי חוקי (666א – ב).

ה. (אליבא דשופטת א' פרקציה):

ד (1) שיטת המשפט בישראל מייחסת חשיבות רבה למוסד הבוררות כמערכת חלופית להכרעה שיפוטית בסכסוכים בין בעלי-דין. המדיניות השיפוטית המושרשת מבקשת לקדם את מנגנון הבוררות המוסכמת בגבולות הדין ולמנוע את קיומה במקרים חריגים בלבד (668ה – ו).

ה (2) סעיף 3 לחוק הבוררות קובע כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. שונה הדבר מקום שצד להסכם בוררות מעלה טענת אי-חוקיות המחייבת ברור ובחינה לצורך ביסוסה. נכונות בית-המשפט להיענות לבקשת צד לבוררות לעכב את הליכי הבוררות לצורך בחינת טענת אי-חוקיות מקום שהיא אינה עולה על פניו של ההסכם, עלולה בנקל לסכל את יעדה המרכזי של הבוררות – לשמש מנגנון מוסכם יעיל ומהיר לפתרון מחלוקות בין צדדים (668ו, 669ב, ד – ה).

ו (3) בנסיבות שבהן אין זה ברור על פניו כי מדובר בהסכם אשר מטיבו אינו יכול לשמש נושא להסכם בוררות בין צדדים, ראוי להתיר את קיומה של הבוררות ולהימנע מבחינה לגופן של טענות אי-החוקיות לפני מעשה (669ז).

חקיקה ראשית שאוזכרה:

- חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, סעיפים 2, 2(א), 2(ב), 2(ב)(1), 2(ב)(3), 3, 3(6), 4, 15א, 47, 47(א)(1).
- חוק הבוררות, תשכ"ח-1968, סעיפים 3, 5, 8, 24(9).
- חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, סעיפים 19, 21, 27, 30, 31.

חקיקת משנה שאוזכרה:

- כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), תשס"א-2001, כלל 2, 3(4).
- כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), תשס"א-2001.
- כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), תשס"א-2001, כלל 4(1).

הצעות חוק שאוזכרו:

- הצעת חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ד-1983.

פסקי-דין של בית-המשפט העליון שאוזכרו:

- [1] ע"א 6222/97 טבעול (1993) בע"מ נ' משרד הביטחון, מינהל ההרכשה והייצור, פ"ד נב(3) 145.
- [2] דנ"א 4465/98 טבעול (1993) בע"מ נ' שפ"הים (1994) בע"מ, פ"ד נו(1) 56.
- [3] בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123.
- [4] ע"א 626/70 שמעוני נ' אולמי לחיים בע"מ, פ"ד כה(1) 824.
- [5] ע"א 3700/98 א.מ. חניות (ירושלים) 1993 בע"מ נ' עיריית ירושלים, פ"ד נז(2) 590.
- [6] דנ"א 3113/03 א.מ. חנויות (ירושלים) 1993 בע"מ נ' עיריית ירושלים (לא פורסם).
- [7] ע"א 10638/02 שטרן נ' יקבי רמת הגולן בע"מ (לא פורסם).
- [8] בג"ץ 6845/00 ניב נ' בית-הדין הארצי לעבודה, פ"ד נו(6) 663.
- [9] ע"א 311/78 הווארד נ' מיארה, פ"ד לה(2) 505.
- [10] ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, פ"ד לו(2) 151.
- [11] ע"א 533/80 אדרעי נ' גדליהו, פ"ד לו(4) 281.
- [12] ע"א 395/87 שלוש נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד מו(5) 529.
- [13] ע"א 157/87 נחשתן נ' זונברג, פ"ד מב(3) 4.
- [14] ע"א 6181/93 סולמונוב נ' שרבני, פ"ד נב(2) 289.
- [15] ע"א 65/85 עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה בע"מ, פ"ד מ(3) 29.
- [16] ע"א 410/64 הררי נ' חברת יהלום בע"מ, פ"ד יט(2) 121.
- [17] ע"א 155/64 אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' פייבלמן, פ"ד יח(3) 195.
- [18] ע"א 550/75 מורלי נ' בגון, פ"ד ל(2) 309.

- [19] ע"א 2/49 רודה נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד ג 201.
- [20] ע"א 312/56 קרבס נ' אברמוביץ, פ"ד יב 115.
- א [21] ע"א 453/74 עובדי בית ברנר שיכון בתל-אביב בע"מ נ' חירותי, פ"ד כט(1) 500.
- [22] ע"א 71/68 קונסטרוקשן אגריגייטס קורפוריישן נ' מפעלי ים המלח, פ"ד כב(1) 695.
- [23] בר"ע 130/71 משיח נ' רביע, פ"ד כה(2) 572.
- [24] ע"א 445/80 ג'ברה נ' המועצה האזורית בקעת בית-שאן, פ"ד לז(1) 421.
- ב [25] ע"א 3/56 סחייק נ' ברנרד, פ"ד יא 441.
- [26] ע"א 247/47 חברת בית-חולים "רפאל" בע"מ נ' פעילון, פ"ד ב 57.
- [27] בר"ע 158/77 סגל נ' נפית השקעות ופיתוח בע"מ, פ"ד לא(3) 389.
- [28] רע"א 2059/98 וולטה יצוב קרקע בע"מ נ' P.R.S. מדיטרניין בע"מ, פ"ד נב(4) 721.
- ג [29] ע"א 581/89 אדרי נ' רונברג, פ"ד מו(5) 679.
- [30] ע"א 307/71 אוניקו רויטמן בע"מ נ' שמשון, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד כו(1) 368.
- [31] רע"א 985/93 אלדינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפרים (ישראל), פ"ד מח(1) 397.
- ד [32] בג"ץ 816/98 אמינוף נ' אלטלף, פ"ד נב(2) 769.
- [33] ע"א 11/56 "אגד" (א.ש.ד.) בע"מ נ' ספיר, פ"ד יב 739.
- [34] ע"א 87/50 ליבמן נ' ליפשיץ, פ"ד ו 57.
- [35] ע"א 108/60 זקס נ' מוסרי, פ"ד יד 2252.
- [36] ע"א 344/83 רויטמן נ' פרס, פ"ד לט(4) 29.
- ה [37] ע"א 60/68 בנין, חברה לביטוח בע"מ נ' הרשקוביץ, פ"ד כב(2) 625.
- [38] המ' 230/58 כ"ץ נ' וולף, פ"ד יג 742.
- [39] ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד, פ"ד מד(1) 75.
- ו פסקי-דין של בתי-המשפט המחוזיים שאוזכרו:
- [40] ה"ע (י-ם) 2/97 מזרחי נ' הממונה על ההגבלים העסקיים (לא פורסם).
- [41] ערר (י-ם) 1/97 איסכור שירותי פלדות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים (לא פורסם).
- [42] ת"א (חי') 10821/97 פז חברת נפט בע"מ נ' ממון (לא פורסם).
- ז [43] ת"פ (י-ם) 209/96 מדינת ישראל נ' אהליך יעקב בע"מ, פ"מ תשס"ב(1) 493.
- [44] ת"א (י-ם) 396/87 קיסין נ' פטרולוג חברת הגז הישראלית (1969) בע"מ (לא פורסם).

[45] ת"א (י-ם) 1000/95 פז חברת נפט בע"מ נ' עמוס, פ"מ תשס"ב (1) 337.

פסקי-דין אמריקניים שאוזכרו: א

- [46] *Associated Milk Dealers, Inc. v. Milk Drivers U. Local 753* 422 F. 2d 546 (1970).
- [47] *Blue Cross and Blue Shield of Michigan v. Michigan Association of Psychotherapy Clinics* 1980-2 Trade Cas. (CCH) P63,351 (1980).
- [48] *Michigan Ass'n of Psychotherapy v. Blue Cross* 325 N.W. 2d 471 (1982).
- [49] *State Oil Co. v. Khan* 522 U.S. 3 (1997).
- [50] *Blue Cross & Blue Shield v. Marshfield Clinic* 65 F. 3d 1406 (1995).
- [51] *Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc.* 433 U.S. 36 (1977).
- [52] *United States v. General Motors Corp.* 384 U.S. 127 (1966).
- [53] *United States v. Sealy* 388 U.S. 350 (1967).

ספרים ישראליים שאוזכרו:

- [54] י' יגור דיני הגבלים עסקיים (מהדורה 2, תש"ס; מהדורה 3, תשס"ב).
- [55] ד' פרידמן, נ' כהן חוזים (כרך ג, בהשתתפות ד' גילה, ע' גרוסקופף, מ' מאוטנר, ב' מדינה, א' פורת, תשס"ד).
- [56] ג' שלו דיני חוזים (מהדורה 2, תשנ"ה).
- [57] ס' אוטולנגי בורות – דין ונוהל (מהדורה 3, תשנ"א).

מאמרים ישראליים שאוזכרו:

- [58] ד' גילה "האם ראוי לפרוץ את סכר ההסדרים הכובלים ולחסום את השיטפון בגדרות אד-הוק? הגיעה השעה לחצוץ בין הסדרים אופקיים לאנכיים" עיוני משפט כז (תשס"ג-תשס"ד) 751.
- [59] ד' גילה "כבילה הפוגעת בתחרות בין הצד הנהנה ממנה למתחריו עיוני משפט (טרם פורסם).
- [60] מ' חת "על דיני ההגבלים העסקיים" המשפט 16 (2003) 84.
- [61] ד' תדמור "הגבלים עסקיים: המאבק לשחרור ההסדרים הכובלים" עיתון הארץ (מדור כלכלה, מיום 3.8.2003).
- [62] ז' אברמוביץ "חידושים בדיני הסדרים כובלים" עסקים וכלכלה – מגזין איגוד לשכות המסחר בישראל 147 (2003) 34.

[63] ד' גילה "לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות אי-תחרות" עיוני משפט כג (תש"ס) 63.

א [64] ד' בכור "הרהורים בחוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959" ספר זוסמן (תשמ"ד) 133.

ספרים זרים שאוזכרו:

ב [65] P.E. Areeda, H. Hovenkamp *Fundamentals Of Antitrust Law* (New York, 2002).

[66] J.O. Von Kalinowski *Antitrust Counseling and Litigation Techniques* (New York, 2003).

ג [67] ABA Section of Antitrust Law *Antitrust Law Developments* (5th ed., vol I, 2002).

מאמרים זרים שאוזכרו:

ד [68] J.R. Allison "Arbitration Agreements and Antitrust Claims: The need for enhanced accommodation of conflicting Public Policies" 64 *N.C.L. Rev.* (1985-1986) 219.

[69] A.J. Dennis "Most Favored Nation Contract Clauses under The Antitrust Laws" 20 *Dayton L.Rev.* (1995) 821.

ה [70] J.B. Baker "Vertical Restraints with Horizontal Consequences: Competitive Effects of 'Most-Favored-Customer' Clauses" 64 *Antitrust L.J.* (1995-1996) 517.

ו בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בירושלים (סגן הנשיא ע' קמא) מיום 18.6.2002 בה"פ 535/01. הבקשה נדונה כערעור. הערעור נדחה כנגד דעתה החולקת של השופטת מ' נאור.

ז י' עמיהוד בן פורת, אורן ארדמן – בשם המבקשת;
ברוך טולידאנו, מרדכי קופרשמידט – בשם המשיבות.

ח

פסק-דין

השופט י' טירקל

א

האם ההסכם שנכרת בין בעלות-הדין הוא הסדר כובל? אם הוא הסדר כובל – ובשל כך בטל מחמת אי-חוקיות – האם בטלה עם ההסכם גם תניית בורות שנכללה בו? אלה השאלות העומדות להכרעתנו.

ב

רקע והליכים

1. בין בעלות-הדין נכרת ביום 9.8.1990 הסכם (להלן – ההסכם), ולפיו ישווקו המשיבות ופיצו פרופילי אלומיניום (להלן – המוצרים) שהמבקשת מייצרת. התנאים העיקריים שנקבעו בהסכם היו אלה: למשיבות יהיו "זכויות הפצה בלעדיות בכפוף להוראות הסכם זה" לשיווק המוצרים באזור תל-אביב "רבתי" (להלן – האזור) (המבוא להסכם); המשיבות יהיו רשאיות להמשיך ולעסוק במכירת מוצרים דומים למוצריה של המבקשת (סעיף 5 להסכם); תקופת ההתקשרות היא שלוש שנים עם אופציה לשלוש שנים נוספות (סעיף 7 להסכם); המשיבות מתחייבות לרכוש מהמבקשת מוצרים במשקל 150 טון מדי חודש (סעיף 8 להסכם); תמורת ההפצה יהיו המשיבות זכאיות לעמלה בשיעור 5% ממחיר כל מכירה (סעיף 10 להסכם); בעלות-הדין הסכימו על המחיר שבו יימכרו המוצרים למשיבות וקבעו שהמבקשת תהיה רשאית להתאימם, מפעם לפעם, למחירי השוק (סעיף 14 להסכם); לגבי המבקשת נקבע כי היא תהיה רשאית למכור את המוצרים ישירות ללקוחות ולמפיצים אחרים באזור בתנאים הנזכרים בהסכם (סעיפים 8, 12 ו-13 להסכם), כמו כן התחייבה המבקשת "שלא למכור מוצרים באזור או בכל מקום אחר בארץ במחירים שהם נמוכים מהמחיר שנדרש מאת המפיצים [המשיבות – י' ט'] לאותו מוצר ולא ליתן תנאי תשלום נוחים יותר..." (סעיף 17 להסכם). הוסכם כי חילוקי דעות יובאו להכרעת בורר דן יחיד שייקבע בהסכמה, ובהיעדר הסכמה ייקבע הבורר על-ידי יושב-ראש לשכת המסחר בתל-אביב (להלן – תניית הבוררות) (סעיפים 27-31 להסכם). סמוך אחרי שכרתו בעלות-הדין את ההסכם כרתו גם תוספת להסכם, ולפיה אם לא יודיעו המשיבות על סיומו של ההסכם בתום תקופתו, תמשיך המבקשת למכור את מוצריה למשיבות. בתוספת להסכם לא נכללה תניית בורות. ביום 9.8.1996 הודיעה המבקשת למשיבות על סיום ההסכם. אין מחלוקת כי המשיבות המשיכו להפיץ את המוצרים עד חודש מארס 2000.

ג

ד

ה

ו

ז

ביום 20.3.2000 הודיעו המשיבות למבקשת כי הפרה את ההסכם בכך שמכרה למפיצים אחרים מוצרים במחיר נמוך מן המחיר שניתן להן, ובכך גרמה להן נזקים

בסכום של כ-15 מיליון ש"ח. בתשובה הודיעה המבקשת למשיבות כי הן שחייבות לה כספים. המשיבות פנו ליושב-ראש איגוד לשכות המסחר וביקשו למנות בורר על-פי ההסכם, וזה הורה למוסד הישראלי לבוררות עסקית – מיסודן של לשכות המסחר – בראשות פרופ' סמדר אוטולנגי, למנות בורר. פרופ' אוטולנגי מינתה את עורך-דין פנחס וולובלסקי להיות בורר (להלן – הבורר). המבקשת טענה לפניו בכתב כי לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 (להלן – חוק ההגבלים העסקיים או החוק), ההסכם הוא הסדר כובל ולפיכך הוא בלתי חוקי. מכאן, שהעניין אינו בסמכותו של הבורר, ויש להעבירו להכרעת בית-המשפט המחוזי בירושלים. הבורר השיב כי לפי כללי הבוררות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית, אין הוא מוסמך לדון בטענה של אי-חוקיות, אלא אם כן הסמיכו אותו לכך שני הצדדים. הבורר ציין כי באפשרותו לפנות באבעיה לבית-המשפט, אולם הביע דעתו "שעדיף – במקום להתנצח בויכוחי פרשנות – שב"כ צפי וקאלמא [המשיבות – י' ט'] יפנה בעצמו, במישורין, אל בית המשפט בבקשה למינוי בורר, שתפטור [צ"ל תפתור – י' ט'] את כל הבעיות".

2. במקביל להליכים אלה הגישה המבקשת, ביום 13.7.2000, לבית-המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסדר דין מקוצר לחייב את המשיבה 1 לבדה לשלם לה סכום של 3,572,993 ש"ח עבור מוצרים שסיפקה לה בתקופה שבין חודש אוקטובר 1999 לבין חודש מארס 2000, שאת תמורתם לא שילמה (להלן – תביעת המבקשת). המשיבה 1 ביקשה מבית-המשפט לעכב את ההליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ולהעביר את המחלוקת לבורר. בית-המשפט המחוזי (כבוד השופט י' עדיאל) דחה בהחלטתו מיום 10.6.2001 את הבקשה לעכב את ההליכים. הוא קבע בהחלטתו שאין עילה לעכב את ההליכים, משום שההסכם המקורי בוטל, ולא הוכח קיומו של הסכם בוררות חדש. בהסכמת המבקשת ניתנה למשיבה 1 רשות להתגונן. תביעת המבקשת תלויה ועומדת.

3. ביום 1.2.2001 עתרו המשיבות לבית-המשפט המחוזי בירושלים על דרך של המרצת-פתיחה בבקשה למנות בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות. המבקשת התנגדה לבקשה מן הטעם שההסכם הוא הסדר כובל ולפיכך בלתי חוקי, ומכאן שהעניין אינו בסמכותו של הבורר. בית-המשפט המחוזי (סגן הנשיא השופט ע' קמא) דחה בפסק-דינו מיום 18.6.2002 את התנגדותה של המבקשת וקבע כי מינויו של הבורר "היה כדין".

המבקשת ביקשה להרשות לה לערער על פסק-הדין. בבקשתה ביקשה לבטל את פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, ולחלופין להחזיר את הדיון לבית-המשפט המחוזי כדי שישמע את טענותיה. המשיבה השיבה על הבקשה.

החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער, והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה.

א

פסק-דין של בית-המשפט המחוזי

4. כאמור, קבע בית-המשפט המחוזי בפסק-דינו כי מינויו של הבורר היה כדין. כפי שאמר, "פקיעת ההסכם, אין בה, כאמור, כדי לחסום את הפניה לבוררות, וכל סכסוך הנוגע לתקופת ההסכם יידון בפני הבורר שנקבע". עם זאת מאחר שלא הייתה הסכמה משותפת ומפורשת לפנות לבורר אחרי שנת 1996, לא ידון הבורר בתביעות המשיבות לגבי הפרות בתקופה שלאחר מכן אלא רק במחלוקות שעניינן התקופה שבין 9.8.1990 ועד 9.8.1996. לעניין ההסכם קבע כי אינו הסדר כובל מן הטעם ש"המבקשות הן המפיעות הבלעדיות ולא היו מפיעים נוספים למוצרים אלו באזור, כך שלא הייתה קיימת תחרות בין המבקשות למפיעים אחרים, ולו למפיעים בכוח. בהעדר תחרות, ולו פוטנציאלית, אין הסדר כובל..."

ב

ג

טענות בעלות-הדין

5. בבקשתה להרשות ערעור טוענת המבקשת, בתמצית, כי ההסכם הוא הסדר כובל לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ההגבלים העסקיים – כבילה לעניין המחיר – ולפי סעיף 2(ב)(3) לחוק – כבילה לעניין חלוקת השוק – ולפיכך הוא בלתי חוקי. מכאן, שהעניין אינו בסמכותו של הבורר. ההסכם גם אינו בא בגדר הפטור שבסעיף 3(6) לחוק – התחייבויות הדדיות לבלעדיות של ספק ושל רוכש – משום שלא הייתה כאן התחייבות הדדית לבלעדיות. המבקשת הוסיפה כי אפילו אם טענתה כי ההסכם הוא הסדר כובל, היא חסרת תוס-לב משום שהייתה צד להסכם ופעלה לפיו, אין בכך "כדי לגרוע מאי-חוקיות העסקה ומחובת בית-המשפט להגן על האינטרס הציבורי". זאת, לפי דעת הרוב בע"א 6222/97 טבעול (1993) בע"מ נ' משרד הביטחון, מינהל ההרכשה והייצור (להלן – פסק-דין טבעול [1]) ובדנ"א 4465/98 טבעול (1993) בע"מ נ' שף-הים (1994) בע"מ (להלן – דיון נוסף טבעול [2]). המבקשת מוסיפה כי כשטענה המשיבה 1 בבקשתה להרשות לה להתגונן נגד תביעתה הנזכרת של המבקשת גם טענת קיזוז, גילתה בכך המשיבה 1 את "רצונה שבית המשפט, ולא הבורר, ידון בטענותיה". עוד טוענת היא כי בית-המשפט המחוזי לא נתן לה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה, כי המשיבות פעלו בתרמית וכי העניין איננו ראוי לדיון בבוררות.

ד

ה

ו

ז

6. המשיבות טוענות בתשובתן כי אין הבקשה מגלה שאלה משפטית או ציבורית המצדיקה מתן רשות לערער ב"ערכאה שלישית" אחרי שדנו בכך הבורר ואחריו בית-

המשפט המחוזי. לעצם העניין טוענות הן כי המבקשת רשאית לטעון טענותיה – לרבות טענת אי-החוקיות – לפני הבורר, שהוא המוסמך להכריע בהן. לעניין ההסכם טוענות הן כי ההסכם אינו בא בגדר הסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק. עוד טוענות הן כי בית-המשפט המחוזי קבע כמימצא עובדתי שלא הייתה פגיעה בתחרות משום שהמשיבות היו מפיצות בלעדיות. במימצא עובדתי כזה אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב, אולם אפילו ההסכם הוא הסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק – דבר המוכחש – יוצא הוא מגדר זה לפי סעיף 3(6) לחוק. עוד יוצא הוא מגדר זה מכוח הפטור שבכלל 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), תשס"א-2001, שהתקין הממונה על ההגבלים העסקיים לפי סעיף 15 לחוק. יתר-על-כן, אפילו אין ההסכם בא בגדר פטורים אלה, אין אי-החוקיות שבהסדר הכובל שבו "מקרינה" על כל סעיפי ההסכם, ותניית הבוררות ממשיכה לעמוד בתוקף. זאת ועוד, ההסכם אינו סותר את תקנת הציבור, ומכאן שהוא חוקי וניתן לדון בו בהליכי בוררות. המשיבות מוסיפות וטוענות כי המבקשת הפרה את ההסכם, ועתה היא עושה שימוש לרעה בהליכים המשפטיים על-מנת לחמוק מהתחייבויותיה. כמו כן מנועה היא מלטעון טענת תרמית משום שלא טענה זאת בתביעתה.

דיון

7. נקדים ונאמר לעניין טענת הסף של המשיבות, כי הדיון לפנינו אינו דיון בערכאה שלישית, משום שהערכאה הראשונה שדנה בעניין הייתה בית-המשפט המחוזי, שדן בבקשה למנות בורר על דרך של המרצת-פתיחה, ולא הבורר. לפיכך אין חלים כאן הכללים המקובלים עלינו לעניין מתן רשות לערער בערכאה שלישית (עיינו, בין היתר, בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ 3[3]). עם זאת העלתה הבקשה להרשות ערעור שאלות משפטיות נכבדות, ומטעם זה ניתנה למבקשת רשות לערער.

הסדר כובל

8. כאמור, טענתה העיקרית של המבקשת היא כי ההסכם הוא הסדר כובל, ולפיכך הוא בלתי חוקי, ומכאן שהעניין אינו בסמכותו של הבורר. טענה זאת מצריכה הכרעה בשאלות שהוצגו בראש פסק-הדין: האם ההסכם הוא הסדר כובל ובשל כך בטל מחמת אי-חוקיות, והאם בטלה עם ההסכם תניית הבוררות שנכללה בו? בהכרעה זאת כרוכים גם שיקולים נוספים: ההגנה על העיקרון של התחרות החופשית המעוגן בדיני ההגבלים העסקיים, שבצדה השאיפה לעודד הליכי בוררות כאמצעי ליישוב מחלוקות בלי להיזקק לערכאות המשפטיות (על האיוון בין השיקולים ראו, בין היתר: ע"א

J.R. Allison 626/70 שמעוני נ' אולמי לחיים בע"מ (להלן – עניין שמעוני [4]);
 “Arbitration Agreements and Antitrust Claims: The need for enhanced
 [68] (accommodation of conflicting Public Policies).”

א

9. לפי סעיף 2(א) לחוק ההגבלים העסקיים:

“הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד
 הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות
 בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין
 אדם שאינו צד להסדר.”

ב

לפי סעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים:

ג

“מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו
 הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

(1) המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;

(2) הריווח שיופק;

ד

(3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או
 סוג האנשים שעמם יעסקו;

(4) כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.”

ה

בצד הגדרתו של ההסדר הכובל בסעיף 2 לחוק פורטו בסעיף 3 לחוק הסדרים שונים
 שהוצאו מגדר ההגדרה שבסעיף 2 לחוק, כמו כן לפי סעיף 4 לחוק, נאסר הסדר כובל
 שלא ניתן לו אישור או היתר על-ידי בית-הדין להגבלים עסקיים או על-ידי הממונה על
 ההגבלים העסקיים. לפי סעיף 15א לחוק, שכותרתו “פטור סוג”, רשאי הממונה על
 ההגבלים העסקיים לקבוע כללים לסוגי הסדרים כובלים אשר צדדים להם יהיו פטורים
 מקבלת אישור בית-הדין. סעיף 47 לחוק עושה את ההתקשרות בהסדר כובל לפלילית
 בכך שהוא מורה, בין היתר, כי מי שהיה צד להסדר כובל שלא אושר או שלא ניתן לו
 היתר, דינו ענישה.

ו

סעיף 2(א) לחוק ההגבלים העסקיים מגדיר אפוא הסדר כהסדר כובל אם הוא מונע
 תחרות בעסקים או מפחיתה. בצדו מונה סעיף 2(ב) לחוק רשימה של עניינים המקימים
 חזקה של פגיעה בתחרות “...מבלי שיהא צורך לבחנם בכל מקרה ומקרה לאור המבחן

ז

הכללי... (דברי ההסבר להצעת חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ד-1983, בעמ' 42). בעקבות דברים אלה נאמר כי "הסדר המכיל את אחת הכבילות המפורטות בסעיף 2(ב) לחוק, חזקה עליו שהוא פוגע בתחרות... כל שצריך להראות זה שההסדר נכלל בגדר אחת החזקות שבסעיף 2(ב) לחוק ומעבר לכך אין צורך להוכיח דבר, אף לא פגיעה בתחרות... מדובר בחזקות חלוטות, אשר אינן מותרות פתח לנסות ולהוכיח את היפוכן" (י' יגור דיני הגבלים עסקיים (מהדורה 3), בעמ' 159-160 והאסמכתאות הנזכרות שם (להלן – יגור [54]); ד' פרידמן, נ' כהן חזים (כרך ג) (להלן – פרידמן וכהן [55]), בעמ' 642; פסק-דין טבעול [1], בעמ' 176-177; דיון נוסף טבעול [2], בעמ' 95-96). לפי השקפתי בדבר הפרשנות המצמצמת של הוראות החוק שראוי לנקוט אותה, כמוסבר להלן, יש מקום להרהר מחדש ב"מוחלטותן" של חזקות אלה. לדעתי, גם יש מקום לעיון מחדש של המחוקק בסוגיה זאת, לרבות בהבחנה בין כבילה במסגרת הסדר "אופקי" לבין כבילה במסגרת הסדר "אנכי", שיידונו בהמשך הדברים.

כבילה במסגרת הסדר "אופקי" מול כבילה במסגרת הסדר "אנכי"

10. מקובל להבחין בין הסדר "אופקי" – הסדר בין גופים מתחרים – לבין הסדר "אנכי" – הסדר בין יצרן לבין משווק או מפיץ. סבורני שכבילה במסגרת הסדר "אופקי" שונה בהשפעתה על התחרות מכבילה במסגרת הסדר "אנכי", ופגיעתה בתחרות חמורה מפגיעתה בתחרות של כבילה במסגרת הסדר "אנכי", לפיכך אין להתייחס לכבילה במסגרת הסדר "אופקי" ולכבילה במסגרת הסדר "אנכי" כאל מיקשה אחת.

גישה זאת עולה, בין היתר, ממאמרו המאלף של ד"ר ד' גילה, המדגיש כי:

"...[ש]פגיעת הסדרים אנכיים בתחרות אינה מובנת מאליה כלל, וקיים שלל הניעות (מוטיווציות) ליגטימיות לעשייתם, שלא כמו בהסדרים האופקיים (הסדרים בין מתחרים או מתחרים-בכוח) מן הסוג החמור ביותר, שאין כמעט הניעות ליגטימיות לעשייתם מלבד הרצון לפגוע בתחרות" (ד' גילה "האם ראוי לפרוץ את סכר ההסדרים הכובלים ולחסום את השיטפון בגדרות אד-הוק? הגיעה השעה לחצוץ בין הסדרים אופקיים לאנכיים" (להלן – גילה [58]), בעמ' 754).

עוד מציין ד"ר גילה כי המגמה המרחיבה של הפסיקה בהגדרת הסכמים כהסדרים כובלים היא בעייתית מכמה סיבות, הכרוכות לדעתו זו בזו:

א

"...ראשית...הרחבה של רשימת הכבילות שייראו כהסדר כובל בלי קשר לפגיעה בתחרות בענף הרלוונטי מכתימה כהסדרים כובלים שלל הסדרים, ובפרט הסדרים אנכיים – בין ספק ללקוח – שאין זה מובן מאליו כלל שהם פוגעים בתחרות... לדעתנו, הסדרים אנכיים אינם צריכים כלל להיות ברשימת כבילות זו..."

ב

...פגיעתם של הסדרים אנכיים בתחרות אינה מובנת מאליה, ויש להם הניעות לגיטימיות רבות..."

ג

ראוי יותר אם כך שבהסדרים אנכיים יוטל הנטל על מי שתוקף את ההסדר להוכיח כי ההסדר עלול לפגוע, באופן בלתי־זניח, בתחרות בענף הרלוונטי. תוצאה זו תושג בנקל על־ידי קביעה כי הסדרים אנכיים אינם נכנסים לגדר סעיף 2(ב) לחוק ההגבלים, המכתימים הסדרים ככובלים בלי קשר לפגיעתם בתחרות" (גילה [58], בעמ' 773-774. וראו גם ד' גילה "כבילה הפוגעת בתחרות בין הצד הנהנה ממנה למתחריו" [59], בסעיף 2; מ' חת "על דיני ההגבלים העסקיים" [60], בעמ' 86 והאסמכתאות שם; יגור [54], בעמ' 162; ד' תדמור "הגבלים עסקיים: המאבק לשחרור ההסדרים הכובלים" [61]; ז' אברמוביץ "חידושים בדיני הסדרים כובלים" [62], P.E. Areeda, [65], at p. 932 (H. Hovenkamp *Fundamentals Of Antitrust Law*).

ד

ה

דברים אלה מקובלים עליי. לפי השקפתי, הרחבת תחומי פריסתו של סעיף 2 לחוק אינה רצויה, וראוי לנקוט פרשנות מצמצמת של הוראות החוק הבאות להגדיר הסדר כהסדר כובל, בין היתר מהטעמים שמניתי בפסק־דין טבעול [1]: האחד, צמצום התוצאות שיש לקביעה שהסדר הוא הסדר כובל בתחום המשפט הפלילי; השני, ייחוס משקל גדול יותר לערכים של תום־לב, הגינות ויושר בהשוואה למשקלה של ההגנה על התחרות החופשית; השלישי, צמצום הפגיעה בוודאות המשפטית על־ידי הפחתת מספר המקרים של ביטול חוזה בשל אי־חוקיות שגורמת הגדרתו כהסדר כובל (פסק־דין טבעול [1], בעמ' 164-165. השוו': ע"א 3700/98 א.מ. חניות (ירושלים) 1993 בע"מ נ' עיריית ירושלים [5]; דנ"א 3113/03 א.מ. חנויות (ירושלים) (1993) בע"מ נ' עיריית ירושלים [6]; ע"א 10638/02 שטרן נ' יקבי רמת הגולן בע"מ (להלן – עניין שטרן) [7]). לכך ניתן להוסיף טעם נוסף, שהוא הצורך להימנע מהגבלת פעילות עסקית מקובלת ורווחת שנועדה להשיג מטרות כלכליות ועסקיות ראויות (ה"ע (י-ם) 2/97 מזרחי נ' הממונה על ההגבלים העסקיים [40]; ביקורת על הפרשנות המרחיבה של המונח "תחרות" בסעיף 2(א) לחוק ראו: פרידמן וכהן [55], בעמ' 645; ד' גילה "לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות אי־תחרות" [63], בעמ' 112).

ז

אומר כבר כאן כי לדעתי ההסכם הנדון בפרשתנו אינו נתפס במצודתו של סעיף 2(א) לחוק, משום שאינו מונע תחרות בעסקים ואינו מפחיתה, ומשום שהוראותיו אינן באות בגדרי הכבילות המפורטות בסעיף 2(ב) לחוק אף-על-פי שלכאורה מדובר בו בהגבלות שעניינן מחיר המוצרים וחלוקת השוק.

כבילה לעניין המחיר

11. שני סוגי כבילות שעניינן מחיר, הבאים בגדר סעיף 2(ב)(1) לחוק, זכו לעיון בפסיקה ובספרות: האחד, תיאום מחיר במסגרת הסדר "אופקי" – כאשר גופים מתחרים קובעים ומתאמים ביניהם את המחיר (Horizontal Price Fixing); השני, קביעת מחיר במסגרת הסדר "אנכי" – כאשר יצרן קובע ומכתיב מחיר למשווק או למפיץ (Vertical Price Fixing) (ראו: ערר (י-ם) 1/97 איסכור שירותי פלדות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים [41]; ת"א (חי') 10821/97 פז חברת נפט בע"מ נ' ממן [42], בפסקה 33; ת"פ (י-ם) 209/96 מדינת ישראל נ' אהליך יעקב בע"מ [43], בעמ' 513-515; יגור [54], בעמ' 162-161; פרידמן וכהן [55], בעמ' 642 ואילך). השאלה הראשונה העומדת לפנינו היא אם הסדר "אנכי", שלפיו יצרן מתחייב כלפי אחד ממפיצי תוצרתו שלא למכור את מוצריו לאחרים במחירים נמוכים יותר או בתנאים טובים יותר מאלה שקבע לו, הוא בגדר כבילה אסורה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק.

הסדרים "אנכיים" שלפיהם יצרן מתחייב כלפי מפיץ או רוכש אחר למכור לו את מוצריו במחירים הנמוכים ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהוא מוכר – המכונים בדין האמריקני "Most Favored Nation" – נדונו בבתי-משפט בארצות-הברית ולא נפסלו. נאמר כי הסדר כזה כלשעצמו אינו בהכרח הסדר כובל, אלא יש לבחון אותו לפי סבירותו. לפי מאמרו של Dennis משנת 1995, הנזכר להלן, בתי-משפט בארצות-הברית לא מצאו הסדרים כאלה כבלתי חוקיים לפי חוקי ההגבלים העסקיים (ראו A.J. Dennis [69] "Most Favored Nation Contract Clauses under The Antitrust Laws" ראו גם: Associated Milk Dealers, Inc. v. Milk Drivers U. Local 753 (1970) [46]; Blue Cross and Blue Shield of Michigan v. Michigan Association of Psychotherapy Clinics (1980) [47]; Michigan Ass'n of Psychotherapy v. Blue Cross (1982) [48]; State Oil Co. v. Khan (1997) [49]). כך לדוגמה נפסק באחת הפרשות, שהסכם בין מרפאה לרופאים שלפיו התחייבו הרופאים כלפי המרפאה לגבות ממנה עבור טיפול בפציינטים תעריף שאינו עולה על תעריף שנדרש מפציינטים אחרים, אינו הסדר כובל משני טעמים מרכזיים: האחד, משום שאין מדובר ב-Price Fixing, ולכן לא קמה חזקה לקיומו של הסדר כובל, ויש לבחון את ההסדר בהתאם למבחן הפגיעה בתחרות. השני,

משום שבחינת ההסדר בהתאם למבחן הפגיעה בתחרות מלמדת על אי־פגיעה; כלשונן של בית־המשפט:

א

“Most Favored nation’ clauses are standard devices by which buyers try to bargain for low prices, by getting the seller to agree to treat them as favorably as any of their other customers. The clinic did this to minimize the cost of these physicians to it, and that is the sort of conduct that the antitrust laws seek to encourage. It is not price-fixing” (הדגשה שלי – י' ט) (*Blue Cross & Blue Shield v. Marshfield Clinic* (1995) [50], at p. 1415).

ב

בספרות שבתחום זה הוצע להבחין בין שני סוגים של הסכמים כאלה: אם היצרן מתחייב כלפי המפיץ שלא למכור את מוצריו למפיעים אחרים במחירים נמוכים יותר או בתנאים טובים יותר מאלה שקבע לו, ההסדר הוא הסדר כובל. אולם אם היצרן מתחייב כלפי המפיץ למכור לו את מוצריו במחירים הנמוכים ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהוא מציע ללקוחותיו, אך היצרן חופשי למכור ללקוחות אחרים במחירים או בתנאים שונים, אין זה הסדר כובל (ראו *J.O. Von Kalinowski Antitrust Counseling and Litigation Techniques* [66], § 7.05).

ג

ד

אעיר כאן כי הסכמים אנכיים מסוג “Most Favored Nation” מקובלים ורווחים בארצות־הברית וכנראה גם בישראל (על תפוצת ההסכמים בארצות־הברית ראו *Dennis, ibid* [69]). ניטיב אפוא לעשות אם נצמצם, ככל האפשר, את הגדרתם הגורפת יתר על המידה של הסכמים כאלה כהסדרים כובלים. בכך גם נמנע את “חניקתה” של פעילות עסקית מקובלת ורווחת שנועדה להשיג מטרות כלכליות ועסקיות ראויות, כאמור לעיל. האינטרס החברתי של קיום תחרות חופשית צריך להישקל בזהירות מול האינטרס החברתי של קיום פעילות עסקית מקובלת בלי שהעוסקים התמימים יהיו, בבלי דעת, לעבריינים (עניין שמעוני [4], בעמ' 829; דעתי בפסק־דין טבעול [1], בעמ' 166, 168 ובדין נוסף טבעול [2], בעמ' 114-113; ת"א (י-ם) 396/87 קיסין נ' פטרולוג חברת הגז הישראלית (1969) בע"מ [44]; ד' בכור “הרהורים בחוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959” [64], בעמ' 138-139).

ה

ו

12. התחייבותה של המבקשת “שלא למכור מוצרים באיזור או בכל מקום אחר בארץ במחירים שהם נמוכים מהמחיר שנדרש מאת המפיעים לאותו מוצר ולא ליתן תנאי תשלום נוחים יותר” (סעיף 17 להסכם), באה לכאורה בגדר אותו סוג של הסכמים שהם הסדרים כובלים (לפי ההבחנה שבחיבורו הנזכר של *Von Kalinowski* [66]).

ז

שהוזכר בסעיף 11 דלעיל), אולם מתוך עיון במכלול סעיפי ההסכם ובדיקתו מבחינת סבירותו, ולאור הגישה המצמצמת שלדעתי יש לנקוט כאמור בהגדרת הסדר כובל, עולה המסקנה שלא חלה כאן חזקת הפגיעה בתחרות שעניינה "המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם", לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק. זאת, בשל כמה טעמים: טעם אחד הוא שלפי סעיף 14(ה) להסכם, "...ידוע למפיצים שמחיר המוצרים כפי שנקבע נכון למועד חתימתו של הסכם זה הוא נמוך מהמקובל בשוק", שמכך ניתן להסיק שאין זה סביר שהמבקשת תמכור לאחרים במחירים נמוכים יותר או בתנאים טובים יותר מאלה שקבעה למשיבות. טעם שני הוא שלפי סעיף 14(ג) להסכם, "אם יחולו בשוק המוצרים שינויים במחירי המוצרים ו/או תנאי התשלום בתקופת תקפו של הסכם זה תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה להתאים את מחירי מוצריה ביחס מתאים למחירי השוק... בעליה או בירידה של מחירים". מכאן ניתן ללמוד על הכוונה שהמחיר והתנאים שייקבעו למשיבות ולמפיצים אחרים יהיו ברמה שווה ובהתאמה למחירי השוק. טעם נוסף הוא בכך שהמבקשת לא קבעה את המחיר שבו ימכרו המשיבות את המוצרים ללקוחותיהן ולא הגבילה את המשיבות בקביעת המחירים שהן דורשות מלקוחותיהן. כמו כן היא לא שללה מעצמה את הזכות לשנות את המחירים ואת התנאים שבהם היא מוכרת את המוצרים למפיצים או לצרכנים.

מן המקובץ עולה אפוא כי ההסכם אינו מונע תחרות ואינו מפחיתה.

כבילה לעניין חלוקת השוק

13. חלוקת שוק לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק ההגבלים העסקיים מתקיימת כאשר בני-אדם המנהלים עסקים מחלקים ביניהם את השוק באופן שפעילותו של כל אחד מהעסקים מוגבלת לחלק מן השוק. נאמר כי "הרעיון הוא שכל אחד מן הצדדים להסדר לחלוקת השוק משריין לעצמו נתח של השוק" (יגור [54], בעמ' 189). הסכמי בלעדיות בטרטוריה מסוימת הם סוג של חלוקת שוק, וההבחנה בין הסכמים אופקיים להסכמים אנכיים קיימת גם בהסכמי בלעדיות כאלה. הסכמי הפצה בלעדיים בין יצרן לספק הם הסדרי בלעדיות אנכיים (יגור [54], בעמ' 222 והאסמכתאות הנזכרות שם), ועם זאת "על אף שהסדר של בלעדיות לא-הדדית בהפצה עלול למנוע או להפחית את התחרות, הוא לא בהכרח יעשה זאת" (החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין: הסדרים כובלים בין יצרני אריזות מקרטון גלי – קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, קובץ ההגבלים העסקיים (כרך ב, תשנ"ו) 66, בעמ' 78).

ההבחנה בין הסכמים אופקיים להסכמים אנכיים הקיימת גם בהסכמי בלעדיות, מקובלת ורווחת גם בארצות-הברית. בפסק-הדין בעניין (*Continental T.V. Inc. v. GTE*) [51] (*Sylvania Inc.* (1977)) הבחין בית-המשפט בין הסדרי בלעדיות גאוגרפיים (Territorial Limitations) לבין הסדרי בלעדיות צרכניים (Customers Limitations). בית-המשפט קבע כי חלוקת שוק על-ידי הענקת זכויות של בלעדיות המתייחסות לסוג מסוים של צרכנים, היא אסורה כשלעצמה "per se", אולם חלוקת שוק על-ידי הענקת זכויות של בלעדיות המתייחסות למיקום הגאוגרפי של המפיצים, אינה אסורה "per se", אלא יש לבחון אותה בכל מקרה ומקרה לפי מבחן הסבירות (ראו גם: גילה [58], בעמ' 762-758 והאסמכתאות שם; *United States v. General Motors Corp.* (1966) ; [53] (*United States v. Sealy* (1967) ; [52]). לפי יגור, "הגיון ההחלטה הנ"ל הוא שלעיתים לגיטימי ליצרן לשאוף ואף לעמוד על כך ש'משני עברי הכביש' לא יהיו שני מפיצים המתחרים ביניהם בממכר מוצריו. בנוסף, בנסיבות מתאימות, אלמלא הגבלה כאמור יתכן והיצרן עצמו לא יצליח לשרוד בשוק, ובסופו של דבר יגרום הדבר להפחתתה של התחרות בשוק ייצור המוצר" (יגור [54], בעמ' 233).

14. "זכויות ההפצה הבלעדיות" לשיווק המוצרים באזור תל-אביב "רבות" שהוענקו למשיבות אינן באות בגדר חלוקת שוק המעניקה זכויות של בלעדיות המתייחסות לסוג מסוים של צרכנים, אלא הן באות בגדר חלוקת שוק המעניקה זכויות של בלעדיות המתייחסות למיקום הגאוגרפי של המכירה. האחרונה דומה במהותה לחלוקת שוק המעניקה זכויות של בלעדיות המתייחסות למיקום הגאוגרפי של המפיצים, שאותה כאמור בוחנת הפסיקה בארצות-הברית בכל מקרה ומקרה לפי מבחן הסבירות. כך גם בפרשה שלפנינו. מתוך עיון במכלול סעיפי ההסכם ובדיקתו מבחינת סבירותו, ולאור הגישה המצמצמת שלדעתי יש לנקוט כאמור בהגדרת הסדר כובל, עולה המסקנה שלא חלה כאן חזקת הפגיעה בתחרות שעניינה "חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו", לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק. יצוין כי המונח "זכויות ההפצה הבלעדיות" שהוענקו למשיבות נכלל רק במבוא להסכם "ובכפוף להוראותיו", ואין בהסכם התחייבות של המבקשת שלא למכור לאחרים מלבד למשיבות בין באזור ובין במקומות אחרים. יתר-על-כן, לפי ההסכם, רשאיות המשיבות להמשיך ולעסוק במכירת מוצרים דומים למוצריה של המבקשת (סעיף 5 להסכם). כמו כן רשאית המבקשת למכור את המוצרים ישירות ללקוחות ולמפיצים אחרים באזור בתנאים הנזכרים בהסכם (סעיפים 8, 12 ו-13 להסכם). ההסכם אינו מונע אפוא את המבקשת ואת המשיבות מלהתקשר עם צדדים שלישיים. ממכלול הוראות אלה עולה שאין כאן חלוקת שוק אסורה (ראו: דברי הביקורת על פרשנות החוק אצל גילה [58], שם; יגור [54], בעמ' 226-227).

ההסכם אינו הסדר כובל – סיכום ביניים

- א 15. מצאנו כי ההסכם אינו הסדר כובל לפי סעיפים 2(א), 2(ב) ו-2(ב) (3) לחוק ההגבלים העסקיים. ממילא אין צורך לדון בשאלה אם ההסכם בא בגדר ההסדרים שהוצאו מגדר סעיף 2 לחוק לפי סעיף 3 לחוק, או אם הוא פטור לפי סעיף 15 לחוק. לפיכך אין הוא בלתי חוקי לפי סעיף 47 לחוק, ומכאן שאינו בטל לפי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים). תניית הבוררות עומדת אפוא על מכונה, והבורר מוסמך לדון במחלוקות שבין בעלות-הדין.

על תניית בוררות בהסדר כובל

16. האם תניית בוררות שנכללה בהסדר כובל בטלה עמו או עומדת על מכונה?

- א לעניין זה ייאמר כי אפילו בא ההסכם בגדר הסדר כובל הבטל מחמת אי-חוקיותו, אין בכך בהכרח כדי לבטל גם את תניית הבוררות. יודגש כי אי-החוקיות הגלומה בהסדר כובל אינה אי-חוקיות בוטה, "שחורה", המטמאת כל מה שהיא נוגעת בו, אלא היא אי-חוקיות "מתונה", "אפורה", במובן זה שאינה מביאה בהכרח לבטלות ההסכם אשר הממונה על ההגבלים העסקיים רשאי להכשירו (סעיף 4 לחוק). יתר-על-כן, אפילו בטל חלק מן ההסכם מחמת אי-חוקיותו, ניתן להפריד בין החלק הפסול לחלק הכשר לפי סעיף 19 לחוק החוזים, ואפילו לא ניתן להפריד בין חלקי ההסכם, ניתן "להחיותו", בשלמותו או בחלקו, על-ידי שימוש בהוראת סעיף 31 לחוק החוזים, שלפיה "...בבטלות לפי סעיף 30 רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון... לחייב את הצד השני בקיום החיוב שכנגד, כולו או מקצתו" (השוו בג"ץ 6845/00 נ"ב נ' בית-הדין הארצי לעבודה [8], בעמ' 714-718; ראו גם: ע"א 311/78 הווארד נ' מיארה [9]; ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני [10], בעמ' 159; ע"א 533/80 אדרעי נ' גדליהו [11]; ע"א 395/87 שלוש נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [12], בעמ' 538-539; ע"א 157/87 נחושתן נ' זונברג [13]; ע"א 6181/93 סולומנוב נ' שרבני [14]; ג' שלו דיני חוזים [56], בעמ' 381; פרידמן וכהן [55], בעמ' 579-581). אפילו היה אפוא ההסכם הסדר כובל ובטל מחמת אי-חוקיותו ניתן להפריד בין החלק הבטל שבו לבין תניית הבוררות, ולחלופין ניתן "להחיות" את תניית הבוררות על-ידי שימוש בהוראת סעיף 31 לחוק החוזים (על החייאת תניית בוררות בהסכם בלתי חוקי ראו ע"א 65/85 עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה בע"מ (להלן – עניין עיריית נתניה [15])).

לא זאת בלבד: הלכה היא כי פקיעתו של חוזה אינה מפקיעה מאליה גם את סעיף הבוררות שבו, אלא יש לבחון כיצד פקע החוזה ומדוע (ס' אוטולנגי בוררות – דין ונוהל [57], בעמ' 106-109). כך נפסק שאי-חוקיות המפקיעה את החוזה אינה מפקיעה את

תניית הבוררות שבו (עניין עיריית נתניה [15]; פרידמן וכהן [55], בעמ' 582-583. לתניית בוררות בחוזה שהסתיים השוו: ע"א 410/64 הררי נ' חברת יהלום בע"מ [16]; ע"א 155/64 אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' פייבלמן [17]; ע"א 550/75 מורלי נ' בגון [18], בעמ' 312. לתניית בוררות בחוזה חדש אחרי שהסתיים החוזה המקורי השוו: ע"א 2/49 רודה נ' סולל בונה בע"מ [19]; ע"א 312/56 קרבס נ' אברמוביץ [20]; ע"א 453/74 עובדי בית ברנר שיכון בתל-אביב בע"מ נ' חירותי [21]. לתניית בוררות בחוזה שהופר לעומת חוזה בטל השוו: ע"א 71/68 קונסטרוקשן אגריגייטס קורפוריישן נ' מפעלי ים המלח [22]; בר"ע 130/71 משיח נ' רביע [23]; ע"א 445/80 ג'ברה נ' המועצה האזורית בקעת בית-ישאן [24], בעמ' 426). גישה זו רואה בתניית הבוררות חלק נפרד מן החוזה, שתוקפה אינו פג גם נוכח בטלות החוזה, ואי-החוקיות שדבקה בחוזה אינה מכתימה את התנייה (פרידמן וכהן [55], בעמ' 583). על כך נאמר, כי:

"...שטר-הבוררות משמש מנגנון ביצוע, היינו מנגנון לביצוע הזכויות הנובעות מן העסקה, נשוא החוזה, ומשום כך אין הכרח, לא מבחינת המשפט ולא מבחינת ההגיון, כי פסול שבחוזה יפסול גם את שטר-הבוררות" (ע"א 3/56 סחייק נ' ברנרד [25], בעמ' 444; ראו גם: ע"א 247/47 חברת בית-חולים "רפאל" בע"מ נ' פעילן [26], בעמ' 78; בר"ע 158/77 סגל נ' נפית השקעות ופיתוח בע"מ [27]).

עוד נאמר:

"...באשר לתוצאות המשפטיות הנובעות מאי-חוקיותו של החוזה, ייאמר, כי אותה אי-חוקיות אינה צריכה לשלול מחברת הפיתוח ומהקשורים בה היזקקות להסכם הבוררות. הוא שריר וקיים לצורך ענייננו ועומד בפני עצמו" (עניין עיריית נתניה [15], בעמ' 58-59).

הערה על תוס'לב

17. משמצאנו כי הבורר מוסמך לדון במחלוקות שבין בעלות-הדין תם הדיון, אולם איני פטור מלהעיר הערה על תוס'לבה של המבקשת.

המבקשת היא חברה מסחרית גדולה שהתקשרה בהסכם בשנת 1990. בעלות-הדין קיימו אותו עד תום תקופתו, לרבות תקופת ארכה, ובסך הכול במשך שש שנים. אחרי שתמה תקופת ההסכם המשיכו בעלות-הדין בקשר עסקי ביניהן במשך ארבע שנים נוספות. לאורך תקופה זאת, עשר שנים רצופות, לא היו בפי המבקשת טענות כלשהן

בדבר חוקיותו של ההסכם ותוקפו. רק אחרי שביקשו המשיבות להעביר מחלוקת בינן לבין המבקשת לבוררות, טענה המבקשת לראשונה כי ההסכם הוא הסדר כובל ובלתי חוקי, וכי אין לדון בו בהליכי בוררות. מותר דומני לומר שטענה כזאת, ובנסיבות כאלה, דבקה בה סירכא של אי-הגינות. על כגון דא אמרתי בפסק-דין טבעול [1]:

א "כאשר מניחים על כף המאזניים האחת את מניעת הפגיעה בתחרות החופשית, שמטרתה לפתח את המשק הלאומי, ועל כף המאזניים השנייה ערכים מוסריים שעליהם אנו מבקשים להשתית את החברה שבה אנו חיים, אין לי ספק שהכף השנייה מכריעה את הראשונה. אם הברירה היא בין חברה עשירה, אך חסרת ערכים, לבין חברה דלה, שערכים על דגלה, אני בוחר בשנייה. אם עומדת התחרות מול אמיתו של החוזה, אמת עדיפה (פסק-דין טבעול [1], בעמ' 167-168; ראו גם: דיון נוסף טבעול [2]; רע"א 2059/98 וולטה יצוב קרקע בע"מ נ' P.R.S. מדיטרנין בע"מ [28]; עניין שטרן [7]).

עוד נאמר על כך :

ט "...תקנת הציבור מחייבת, בראש ובראשונה, שאדם יכבד הסכם והתחייבות, שקיבל על עצמו ברצון חופשי, בידעה ברורה ובהבנה מלאה של פרטי העיסקה. המערערים דנן עשו ככל אשר לאל ידם כדי לפגוע ביסוד מוסד זה של כיבוד החוק, ומשכלו כל הקצין, ודבר זה לא עלה בידם, טרחו ומצאו, כי ההסכם דנן נגוע הוא באי-חוקיות... התנהגות זו של המוכרים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, מחייבים את בית המשפט במשנה זהירות בבואו לדון בטענתם זו בדבר אי-אכיפת החוזה" (ע"א 533/80 הנ"ל [11], בעמ' 291; ראו גם: ענין שמעוני [4], שם; ע"א 335/78 הנ"ל [10]; ע"א 581/89 אדרי נ' רוזנברג [29]. ראו והשוו גם פרידמן וכהן [55], בעמ' 584-587).

סוף דבר

18. ההסכם אינו הסדר כובל. אפילו היה כזה לא היה בכך כדי לקבוע, מניה וביה, שאי-החוקיות הגלומה בו, לפי סעיף 4 לחוק ההגבלים העסקיים, עושה את ההסכם כולו – לרבות תניית הבוררות שבו – בטל מכוח סעיף 30 לחוק החוזים. הבורר מוסמך אפוא לדון במחלוקת שבין בעלות-הדין כפי שקבע בית-המשפט המחוזי.

19. לא מצאתי ממש בכל יתר טענותיה של המבקשת. אעיר כי המשיבה 1, שטענה טענת קיזוז במסגרת בקשתה להרשות להתגונן בתביעת המבקשת, לא הסכימה בכך לוותר על תניית הבוררות שבהסכם. טענת קיזוז בהליך אחד אין לפרש אותה, בהכרח, כויתור על טענה אחרת בהליך אחר. יתר-על-כן, תביעת המבקשת עניינה התקופה שאחרי פקיעת ההסכם, ובתקופה זאת אין תניית הבוררות תקפה כפי שקבע בית המשפט המחוזי. גם בטענת המבקשת כי בית-המשפט המחוזי לא נתן לה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה אין ממש. כאמור, הוגשה בקשתן של המשיבות למנות בורר על דרך של המרצת-פתיחה, ונתבררה על-פי התצהירים שהוגשו. כפי שעולה מן הפרוטוקול, לא נתבקשה חקירה של המצהירים, ולא נתבקש טיעון נוסף בעל-פה.

20. לפיכך נדחה הערעור.

המבקשת תשלם למשיבות שכר טרחת עורך-דין בסך 30,000 ש"ח.

השופטת מ' נאור

1. בבקשתן למינוי בורר הסתמכו המשיבות (שיכנוו להלן – צפי וקאלמא או המפיצים) על הוראת סעיף 17 להסכם בינן לבין המבקשת (שתכונה להלן – אקסטל). סעיף זה דן באחת מהתחייבויותיה של אקסטל והיא זו:

"שלא למכור מוצרים באיזור או בכל מקום אחר בארץ במחירים שהם נמוכים מהמחיר שנדרש מאת המפיצים לאותו מוצר ולא ליתן תנאי תשלום נוחים יותר..."

2. צפי וקאלמא מבקשות להגיש בפני בורר תביעה שעילתה היא הפרת ההתחייבות שבסעיף 17 הנזכר. בסעיף 7 לבקשה למינוי בורר טוענות הן כי אקסטל גבתה מהן עבור מוצרים מחירים גבוהים מאלה שהתחייבה לתת להן, ובכך גרמה להן נזקים ישירים ועקיפים, אשר מסתכמים יחד לנזק העולה על 20 מיליון ש"ח לכל אחת מהן. מההתכתבויות שצורפו לכתבי-הדין עולה שהטענה היא כי אקסטל מכרה סחורה לכמה לקוחות (בעיקר לאלומיניום "זוהר) במחירים הנמוכים משמעותית מן המחירים שחויבו בהם המבקשות. הדבר נעשה, כך נטען, באופן מתוחכם: הלקוחות שנהנו מהמחיר המועדף חויבו תחילה במחיר הרגיל, ואחר כך קיבלו זיכויים כך שבסופו של דבר שילמו מחיר נמוך מהמחיר ששילמו צפי וקאלמא.

- א 3. מסקנתי בשאלה אם לפנינו הסדר כובל היא שיש לפנינו הסדר כובל. הסדר כובל זה אינו עומד בשוליה של המחלוקת שבגינה התבקש מינוי בורר; סעיף 17 להסכם עומד בלב לבה של התביעה שהמפיעים מבקשים להגיש בפני בורר. עמדתי שלי היא כי סכסוך זה אינו יכול להיות מוכרע בבוררות, ועל-כן אין מקום למינוי בורר. אם ברצון המפיעים לתבוע – המקום הנכון לעשות כן הוא בבית-המשפט. ועוד, שאלת הפרת סעיף 17 להסכם ממילא תלויה ועומדת בבית-המשפט במסגרת טענת קיזוז שהעלתה קאלמא בתביעתה של אקסטל. אף זהו טעם טוב, בנסיבות העניין שבפנינו, שלא להעביר את המחלוקת לבוררות שתתנהל במקביל לתביעה.
- ב

על הסדרים כובלים – אקדמות מילים

- ג 4. נצטט שוב לנוחות הקורא, את סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים (להלן – חוק ההגבלים העסקיים או החוק).

ד "הסדר כובל" 2. (א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

ה (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

- ו (1) המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;
- ז (2) הריווח שיופק;
- ח (3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;
- ט (4) כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם."

- י 5. חברי השופט טירקל מציע לנו לקבוע כי הסדרים אנכיים אינם נכנסים בגדר סעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, המכתיים הסדרים ככובלים בלי קשר לפגיעה בתחרות. חברי מציע לנו לאמץ, בין השאר, את עמדתו של ד"ר ד' גילה במאמרו המאלף שקטעים ממנו צוטטו על-ידי חברי (גילה, במאמרו "האם ראוי לפרוץ את סכר

ההסדרים הכובלים ולחסום את השיטפון בגדרות אד-הוק? הגיעה השעה לחצוץ בין הסדרים אופקיים לאנכיים" [58]. וכך מסכם גילה את עמדתו:

א

"...הסדרים אנכיים יוכלו להיות הסדרים כובלים רק לפי סעיף 2(א) לחוק ההגבלים העסקיים, קרי רק אם הם עלולים לפגוע בתחרות, בענף רלוונטי כלשהו, באופן לא זניח. ...לעומת זאת, סעיף 2(ב) לחוק, המכתיב הסדרים ככובלים בלי קשר לפגיעתם בתחרות, יחול רק על ההסדרים האופקים החמורים ביותר. פגיעתם של הסדרים אלה בתחרות מובנת מאליה כמעט... רוב ההסדרים האופקיים הללו ייכללו גם ברשימת הכבילות שלא יוכלו להינות מפטור הסוג להסדרים שפגיעתם בתחרות קלת-ערך. רק בהסדרים מעין אלה יהא בית-משפט אזרחי פטור מן הניתוח הכלכלי האומד את פגיעת ההסדר בתחרות בענף הרלוונטי" (שם [58], בעמ' 751-752; ההדגשה שלי – מ' נ').

ב

ג

מאמרו הנזכר של גילה עוסק בפסק-דינו של בית-משפט זה בע"א 3700/98 הנ"ל (להלן – פרשת חניות [5]). בפרשת חניות [5] קבעו כל השופטים, אף שהנמקותיהם שונות, שבנסיבות שתוארו שם לא היה הסדר כובל. עתירה לדיון נוסף על פסק-הדין נדחתה: דנ"א 3113/03 הנ"ל [6]. מאמרו של ד"ר גילה נכתב לפני ההחלטה הדוחה את הבקשה לדיון נוסף.

ד

6. בתי-המשפט ובית-הדין להגבלים עסקיים התלבטו רבות, משך שנים ארוכות, בשאלת פרשנותו של סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים על שני חלקיו. התחושה שלפיה פרשנות מילולית של הסעיף עלולה ללכוד במצודתה כמעט כל הסכם, עולה עוד מפסק-הדין שניתן לפני למעלה משלושים שנה: ע"א 626/70 הנ"ל [4] (הנזכר גם בפסק-דינו של השופט ריבלין בפרשת חניות [5]).

ה

7. בית-משפט זה עסק זה לא מכבר בהרחבה בפרשנותו של חוק ההגבלים העסקיים ובמבנהו בפרשת טבעול: דנ"א 4465/98 (להלן – פרשת טבעול [2]). משניתן פסק-הדין בהרכב המורחב נראה כי בא סוף סוף גואל לשאלת פרשנותו של סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים. בית-המשפט קבע (ברוב דעות), בין השאר, כי החזקות המפורטות בסעיף קטן (ב) של סעיף 2 שצוטט לעיל, חזקות חלוטות הן. בהתקיים אחת מהחזקות החלוטות אין צורך להוכיח שהייתה בפועל פגיעה בתחרות כדי שייקבע קיומו של הסדר כובל. הדברים פורטו בהרחבה, ואין צורך לחזור ולפרט.

ו

ז

8. בדעה המובעת על-ידי גילה, שחברי מציע לאמץ אותה, יש קסם רב כהצעה למחוקק. היא מבוססת על הבחנות מקובלות במשפט המשווה. לא ניתן לדעתי לקבלה כחלק מהדין המצוי בישראל. לא נוכל לדעתי לקבוע, בדרך של פרשנות, את שמציע לנו גילה. לעניין זה יפים דבריו של השופט מ' חשין, שביטא את דעת הרוב בפרשת טבעול [2] ביחס לטענתה של טבעול כי ההסדר שעשתה אינו הסדר כובל לפי הדין האמריקני. וכך אמר:

ב "לחלותו של המשפט האמריקני על ענייננו

50. טבעול הפנתה אותנו אל הדין האמריקני, ולטענתה הסדר הכבילה שלפנינו הסדר כשר הוא לפי דין זה. טיעונה זה של טבעול מדרש פליאה היה בעיניי. ראשית לכול, הדין האמריקני אינו דין בישראל, ונתקשיתי להבין מה הוא טיעונה של טבעול ויישמע. יתר-על-כן, דרכו של המשפט האמריקני בנושא ההסדרים הכובלים שונה היא מדרכנו-שלנו; שלפי דין ישראל יכול שיהיה הסדר כובל, אך אותו הסדר יזכה להכשר באמצעות מנגנונים שקבע החוק (ואשר הזכרנו אותם למעלה), בעוד אשר בהתאם לדין בארצות-הברית אין מנגנון להכשיר את הטרף. אין צורך בדמיון מפליג כדי להבין ולידע כי עצם קיומו של מנגנון הכשרה מביא, על דרך ההילוך לאחור, להגדרה שונה של הסדר כובל. פירוש: משפט ישראל יכול להתיר לעצמו להגדיר הסדר כובל ברחבות-יתר, על יסוד הנחה שיהיה ניתן להכשיר את הבלתי כשר. די בשוני זה בין שתי שיטות המשפט כדי שנתעלם מטיעוניה אלה של טבעול כטיעונים בלתי רלוונטיים. אכן כן, ניתן להיעזר בו במשפט ארצות-הברית להיקש, ובוודאי ללימוד עקרוני החוק. כך – אך לא למעלה מכך. להפסי דעתה של טבעול נוסף – כאימרת-אגב – כי הסכם האי-תחרות שנעשה בין בעלי-הדין הסכם פסול הוא לכאורה גם לפי הדין בארצות-הברית. השוו: *Blackburn v. Sweeney* [53 F. 3d 825] (1995) "פרשת טבעול [2], בעמ' 102).

9. סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים, שצוטט לעיל, אינו מבחין בין הסדרים אופקיים להסדרים אנכיים. לדעתי, ועם כל הקסם שבהצעה, לא נוכל להכניס את ההבחנה המוצעת בדרך של פרשנות. כשלעצמי, אין לי הסתייגות מהפרשנות שניתנה לסעיף 2 לחוק בפרשת טבעול [2] כדין מצוי. אוסיף ואומר כי אפילו הייתה לי הסתייגות ממה שנקבע, הרי לאחר שנפסק מה שנפסק בפרשה זו אך לפני זמן קצר ובהרכב מורחב, לא הייתי ממחרת להציע לסטות מההלכה שנפסקה.

10. ההבחנות שגילה מציע לנו בין הסדרים אופקיים להסדרים אנכיים, וההבדלים בהשלכותיהם על התחרות שעליהם הצביע, אינם זרים לדיני ההגבלים העסקיים בישראל. יש להם משמעות מקום שההסדר נבחן בפריזמה של סעיף 2(א) לחוק (ראו למשל ת"א (י-ם) 1000/95 פז חברת נפט בע"מ נ' עמוס [45], בעמ' 365-366 בפסק-דינה של חברתי השופטת פרוקצ'יה והאסמכתאות שם). להבחנות האמורות יש מקום גם בשיקוליו של בית-הדין להגבלים עסקיים כשהוא נדרש לשאלה אם לאשר הסדר כובל או לא לאשרו.

11. ואולם חברי מציע לנו לקרוא אל תוך סעיף 2 לחוק, המגדיר מהו הסדר כובל, הבחנות שאין להן לדעתי עיגון בלשונו של החוק. הצעה זו קשה לי כאמור לקבל. הצעה זו ראויה לעינו של המחוקק. את ההסדר הכולל יצר המחוקק, והוא, ורק הוא, המוסמך לשנותו. כפי שנאמר בדנ"א 3113/03 חנ"ל [6] הנזכר:

"חוק ההגבלים העסקיים פורש עצמו על-פני מרחבים אדירים, וכבודו מאופק-אל-אופק. המחוקק יכול היה לטפל בנושא ההגבלים העסקיים בדרך אחרת משבחר ללכת בה, ואולם משבחר ללכת בדרך שבחר בה, נטל הוא המוטל עלינו – כבכל מעשה של פרשנות דבר-אמנות – לפרש את החוק ולהחיל את הוראותיו על אירועי החיים בשום-שכל ובטוב-טעם".

12. אוסיף ואומר כי בעיניי יש יתרונות רבים לקביעת סוגי עניינים שלגביהם ישנה חזקה חלוטה בדבר קיומו של הסדר כובל כפי שנפסק בפרשת טבעול [2]. בבית-הדין להגבלים עסקיים נשמעים לא אחת מומחים העוסקים בשאלה – שאינה פשוטה כשלעצמה – מה השפעתו של הסדר זה או אחר על התחרות. ההליך האזרחי ה"רגיל" אינו מתאים לכך. גילה מצביע במאמרו [58], תוך ביקורת, על כך שבפרשת חניות [5] לא נעשה ניתוח כלכלי של השפעת ההסדר שנדון שם על התחרות. הוא מציג שאלות שבית-המשפט לא עסק בהן בפרשת חניות [5], כגון מהו שוק המוצר הרלוונטי? האם השוק הרלוונטי הוא לא מקומי באופיו? מיהם המתחרים המשמעותיים בשוק הרלוונטי? וכל כיוצא באלה שאלות שבית-הדין להגבלים עסקיים מורגל בהן. אלו שאלות מורכבות ה"צורכות" זמן שיפוטי לא מועט. חזקות חלוטות, והכול במקרים הראויים, יש בהן כדי לצמצם את היקף הבירור בהליך השיפוטי ה"רגיל" ולהקל עליו. אם יש צורך בחשיבה חדשה בשאלה אם אכן כל החזקות שבסעיף 2(ב) לחוק אכן טובות וראויות הן, זהו עניין למחוקק – ולא לבית-המשפט – לענות בו. בית-המשפט אינו יכול לא להוסיף ולא לגרוע. גם קביעה שיש לתת לחוק פרשנות מצמצמת אין בה כשלעצמה כדי להציב פתרון כולל וקוהרנטי לשאלה מהו (ומה איננו) הסדר כובל.

13. על-כן – ובלי לגרוע מעוצמתן של ההצעות מבחינת הדין הרצוי – דרכי שלי תהיה בתלם ההלכה הפסוקה בפרשת טבעול [2].

א

ההסכם שבין הצדדים

14. לדעתי, חלה על סעיף 17 להסכם החזקה החלוטה שבסעיף 2(ב)(1) לחוק ההגבלים העסקיים, ולפיה יראו כהסדר כובל כבילה בעניין "המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם". אכן, המחיר עצמו אינו נקוב בהסכם, ומותר לאקסטל לשנותו, ואולם משמעותו של ההסכם היא שאם למפיצים אקסטל מוכרת את המוצרים ב-X שקלים, היא לא תוכל למכור אלומיניום "זוהר" (או לכל מפיץ אחר) במחיר הנמוך מ-X. כך פשט הכתוב, וכך בדיוק טוענים המפיצים. "המחיר שיידרש" מאחרים על-ידי אקסטל הוא אפוא מחיר שאינו נמוך מהמחיר שמשלמים המפיצים בהסכם. אקסטל מגבילה אפוא את עצמה בהסכם באופן העלול למנוע, או להפחית את התחרות בעסקים בין צפי וקאלמא לבין כל אדם שאינו צד להסכם (מפיצים אחרים) לגבי המחיר שתדרוש ממפיצים אחרים. כיוון שעל-פי פסיקתו של בית-משפט זה בפרשת טבעול [2] החזקות שבסעיף 2(ב) קובעות כללים של מהות, שוב אין צורך לבחון אם הייתה בפועל פגיעה בתחרות במידה בלתי סבירה, עם זאת לא מן המותר להעיר שאף שההסדר בין הצדדים שלפנינו הסדר אנכי הוא, השפעותיו של סעיף 17 הן דווקא השפעות אופקיות. הסעיף מגביל את התחרות בין צפי וקאלמא לבין כל מפיץ פוטנציאלי אחר של מוצריה של אקסטל בכל מקום (ראו והשוו יגור בספרו הנ"ל (מהדורה 2) [54], בעמ' 179-180, בסעיף "הטעמים לאסור על קביעת מחיר אנכית").

ה

15. בצדק מצביע חברי על כך שסעיף 17 להסכם משקף פרקטיקה עסקית מקובלת הידועה בכינויים "Most-Favored Nation" clause (MFN) או "Most Favored Customer" Clause. סעיפים אלה מבטיחים לרוכש שהוא יקבל מהמוכר, למצער, את התנאים הטובים ביותר שייתן המוכר ללקוח אחר כלשהו שלו (ראו: ABA Section of Antitrust Law Antitrust Law Developments [67], at p. 147. סעיפים כאלה עשויים לפגוע בתחרות בין מי שנהנה מסעיף כזה לבין רוכשים אחרים, כיוון שהם תמריץ למוכר לדרוש מהמתחרים האחרים מחיר גבוה מזה שהיה דורש אלמלא הסעיף האמור, כדי להימנע מהפרת ההתחייבות ללקוח המחזיק בתנאי המועדף. זאת הרי בדיוק טענת המפיצים בענייננו. הם טוענים שהופרה כלפיהם התחייבות, כי אחרים רכשו בפועל מאקסטל במחיר נמוך יותר, ועל-כן זכאים הם לפיצוי. J.B. Baker במאמרו: "Vertical Restraints with Horizontal Consequences: Competitive Effects of 'Most-Favored-Customer' Clauses" [70] על כך שישנם הסדרים אנכיים העשויים להשפיע על התחרות במישור האופקי. הוא מתמקד במאמרו בהסכמים אנכיים שיש

ט

בהם תניית MFN כהסכמים העשויים להשפיע על התחרות ממש כמו הסכמים אופקיים, בדרכים שונות שעליהן הוא עומד בהרחבה. Baker מבקש להרהר אחר ה"אקסיומה" שלפיה "הסכמים אנכיים הם רעים; הסכמים אופקיים הם טובים". אכן, לגבי הסכמים הכוללים תניות מסוג MFN עדין לא נטען במשפט האמריקני כי הם לא חוקיים *per se*, והם נבחנו עד כה במסגרת ה"rule of reason" (ראו ABA *supra* [67], at pp. 147-148). שיטתנו, כפי שפורט בהרחבה בפרשת טבעול [2], אחרת היא. את החזקות החלוטות שבסעיף 2(ב) לא ניתן לסתור, ולדעתי – החזקה החלוטה חלה בענייננו. כפי שבואר בפרשת טבעול [2], העובדה שמדובר בהסדר כובל איננה סוף פסוק. בעת עשיית ההסכם היה ניתן לבקש להכשירו בבית-הדין להגבלים עסקיים. כיום ישנם גם פטורי סוג, סוגיה שאעמוד עליה ביתר הרחבה בהמשך הדברים.

16. אקסטל טוענת, לחלופין, שמדובר בעניין של מה בכך. אין בידי לקבל טענה זו. המפיצים טוענים שהפרת סעיף 17 להסכם גרמה לכל אחד מהם נזק של 20 מיליון ש"ח. קשה לומר שהסדר כובל זה הינו עניין של מה בכך (ראו והשוו פרשת חניות [5], דעת השופט אור).

17. אשר לשאלה אם ההסכם פוגע בתחרות בפועל, אעיר כי אין לפנינו ניתוח כלכלי של השוק הרלוונטי מפי מומחים (לסוגיית הגדרת השוק הרלוונטי ראו מאמרו הנזכר של גילה [58], וכן בספרו הנ"ל של יגור (מהדורה 2) [54], בעמ' 144-206). בתגובה של צפי וקאלמא לתשובת אקסטל לבקשה למינוי בורר שהוגשה לערכאה הראשונה, צוין כי בזמן הרלוונטי להסכם – עד שנת 1996 – החזיקה אקסטל, בהתאם להערכה מרחיבה, רק כ-20% מענף ייצור האלומיניום במדינת ישראל, וחלקם של המפיצים באזור היה כ-6% בלבד. ואולם אפילו היינו מניחים (ולאחר פרשת טבעול [2] לא נוכל להניח כך) שהחזקה שבסעיף 2(ב)1 לאו חזקה חלוטה היא, הנטל להביא נתונים לסתירת החזקה, שלפיה הכבילה בעניין המחיר משפיעה על התחרות, מוטל על המפיצים. אין די בציון הנתונים האמורים כדי להגיע למסקנה שאין בהסכם השפעה על התחרות. בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), תשס"א-2001, שהתקבלו שנים רבות לאחר ההסכם, ישנה חזקה שהסכם פוגע פגיעה קלת ערך בתחרות אם נתח השוק המצרפי של כל הצדדים לו בשוק המוצר אינו עולה על 10% משוק כאמור. אף שהכללים אינם חלים, הזכרתי נושא זה כדי להראות שהנתונים הדלים שהובאו בעניין שוק המוצר, לא די בהם כדי לעמוד בנטל הראיה אפילו היה ניתן לסתור את החזקה.

18. לשיטתי, כיוון שמדובר בהסדר כובל, יש צורך לבחון גם את תחולת החריגים: ההסכם אינו נופל אף בגדר אחת משורת ההסדרים המנויים בסעיף 3 לחוק ההגבלים

העסקיים, שלגביהם נקבע שעל־אף האמור בסעיף 2 הם אינם נחשבים להסדרים כובלים. לא חל על ענייננו סעיף 3(6), הקובע:

א

"הסדרים שאינם
הסדרים כובלים 3. ...

(6) הסדר בין רוכש נכס או שירות לבין ספק, שכל כבילותיו הם התחייבות הספק שלא יספק נכסים או שירותים מסויימים, לשם שיווק, אלא לרוכש, ובהתחייבות הרוכש לרכוש אותם נכסים או שירותים רק מהספק, ובלבד שהספק והרוכש, שניהם, אינם עוסקים בייצור אותם נכסים או במתן אותם שירותים; הסדר כאמור יכול שיהיה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו.

ב

ג

"...

ד

אמנם, בענייננו מדובר בהסדר בין רוכש נכס לבין ספק, ואולם אין מדובר בהסכם הפצה בלעדי דו־כיווני (ראו יגור בספרו הנ"ל (מהדורה 2) [54], בעמ' 180-181, 214-219). סעיף 5 להסכם קובע מפורשות שאין בהסכם כדי למנוע מהמפיצים להמשיך ולעסוק בשיווק מוצרים של יצרנים אחרים, על־כן החריג שבסעיף 3(6) לחוק אינו חל.

ה

19. כאמור, בעת עשיית ההסכם ובמשך שנות הפעלתו עדיין לא היו בנמצא "פטורי סוג". סעיף 15 לחוק ההגבלים העסקיים חוקק רק בשנת תש"ס, על־כן אין מקום לעסוק בשאלה אם כיום היה ההסכם נופל בגדר פטור סוג זה או אחר (ראו והשוו בפרשת חניות [5], דעת השופט אור). בבחינה למעלה מהצורך אעיר כי סעיף 4(1) לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) תשס"א-2001 קובע כי זולת אם נאמר אחרת בכללי "פטור סוג", לא יחול "פטור סוג" על הסכם הכולל, במישרין או בעקיפין, כבילה בעניין תיאום מחירים שיוצרו, יידרשו או ישולמו, או הכתבתם; אין חלים לכאורה כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) ולו בשל הוראת סעיף 3(4) לכללים אלו, המורה שפטור הסוג בכללים אלה לא יחול על הסכם הפצה בלעדית, כשבין הצדדים קיים הסכם לעניין "המחיר שבו יציעו המוכר, הספק או אדם אחר מטעם מי מהם את הטובין לאחר". על־כן לכאורה, ובלי לקבוע מסמרות בעניין זה, גם היום לא היה ההסכם נופל לגדר פטור סוג.

ז

20. ההסדר בין הצדדים הסדר כובל הוא לדעתי גם משום שחלה עליו חזקה חלוטה נוספת – זו הקבועה בסעיף 2(ב)(3) – הסדר של חלוקת שוק. בעניין זה איני רואה צורך להרחיב נוכח מסקנתי שחלה החזקה החלוטה שבסעיף 2(ב)(1). נושא חלוקת השוק אינו עומד בלבד של המחלוקת שלגביה מבקשים למנות בורר.

א

21. סוף דבר: דעתי היא שההסכם בין הצדדים הסדר כובל הוא.

מינוי בורר?

ב

22. לדעתי, לא היה מקום למינוי בורר בפרשה זו. שני טעמים לדבר, ודי בכל אחד מהם בנפרד כדי להביא למסקנה האמורה: הטעם האחד הוא שבשאלה מושא הבוררות תלוי ועומד הליך בבית-המשפט; הטעם השני נעוץ בכך שכלב המחלוקת עומד הסדר כובל.

ג

הליכים תלויים ועומדים

23. בין קאלמא (בלבד) לבין אקסטל תלויים ועומדים הליכים אחרים בבית-המשפט המחוזי. בית-המשפט המחוזי החליט שלא להיעתר לבקשת קאלמא לעכב את ההליכים בתביעה שהגישה אקסטל משום שלא הוכח שגם בתקופה שלאחר תום ההסכם הכתוב היה הסכם בוררות. על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור, והתביעה האזרחית של אקסטל תלויה ועומדת. התביעה עצמה נוגעת לתקופה שלגביה אין הסכם בוררות. קאלמא התגוננה בפני תביעת אקסטל והעלתה טענת קיזוז. טענת הקיזוז מבוססת, על-פי כתבי-הטענות שבפנינו, על הפרת סעיף 17 להסכם בתקופה שבה היה ההסכם בתוקף, דהיינו עד שנת 1996. עיון בכתבי-הטענות מעלה שאותן טענות עצמן (לרבות התחשיב הנלווה להן) שמבקשת קאלמא להעלות בבוררות, עתידות להתברר במסגרת טענת הקיזוז כחלק מההליך האזרחי התלוי ועומד. זו לדעתי סיבה מספקת שלא למנות בורר בין אקסטל לבין קאלמא לשם הגשת תביעה של קאלמא בבוררות (ראו והשוו: ע"א 307/71 אוניקו רויטמן בע"מ נ' שמשון, חברה לביטוח בע"מ [30]; רע"א 985/93 אלרינה אינווטטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפרים (ישראל) [31]). אם תתברר המחלוקת גם בהליך האזרחי וגם בבוררות, יש חשש לקביעות סותרות. אכן, צפי איננה צד להליך זה אף ששמה נזכר שוב ושוב בבקשת הרשות להתגונן (שהפכה לכתב-הגנה) כמי שעניינה זהה לעניינה של קאלמא. הטענה שבפי צפי ובפי קאלמא היא אותה טענה: הפרת סעיף 17 להסכם. נראה לכאורה שצפי וקאלמא הינן "חליפות" לצורך סוגיית מעשה-בית-דין. אך גם אם לאו, אין זה יעיל לדון באותה הסוגיה של הפרת סעיף 17 בשתי ערכאות במקביל. ראוי שעניינה של צפי – אם אכן יש לברר

ד

ה

ו

ז

בנפרד – יתברר רק לאחר ההליך שבין אקסטל לקאלמא. כך או אחרת – סוגיית הפרת ההסכם תלויה ועומדת בבית-המשפט במסגרת טענת הקיזוז שהעלתה קאלמא כמגן מול התביעה שהגישה אקסטל. טענת הקיזוז "החזירה" את ההליך נושא התביעה לתקופה שבה היה ההסכם בתוקף. על-כן אין זה ראוי לדעתי לברר את המחלוקת במסגרת בורות בהיותה תלויה ועומדת בבית-המשפט.

בוררות בטוגיית הסדר כובל?

24. ראינו כי הטענות שמעלות צפי וקאלמא, שלפיהן אקסטל הפרה את הוראות סעיף 17 להסכם, נמצאות בלב בלה של התביעה. משהגעתי לכלל מסקנה שסעיף 17 להסכם יוצר הסדר כובל, לדעתי אין מקום לברר את המחלוקת בבוררות. לעניין זה דעתי כדעת יגור בספרו הנ"ל (מהדורה 2) [54], בעמ' 605-606: הסדר כובל (שלא זכה לאישור של בית-הדין להגבלים עסקיים) משפיע לא רק על הצדדים לו, אלא פוגע בתחרות בשוק, כלומר בציבור כולו – בצרכני המוצר ובמתחרים פוטנציאליים חדשים שהיו עשויים להיכנס לשוק אלמלא ההסדר הכובל. אין זה ראוי שהסדר כובל (שהוא גם עבירה פלילית) ידון בבוררות. לדעתי, קביעת סעיף בורות בהסכמים שבלבם הסדר כובל עשויה לטאטא הצדה, הרחק מהעין הציבורית הבוחנת, הסדרים כאלה.

25. מקובל עליי שניתן לעתים להעביר "עפרון כחול" ולדון במסגרת בורות גם בהסכם שאחד מסעיפיו – שאינו בלב הסכסוך – הוא הסדר כובל (ראה ס' אוטולנגי בורות – דין ונוהל (להלן – אוטולנגי [57]), בעמ' 57 ה"ש 24). גם דעתי היא כי אין למנוע בירור מחלוקות שאינן "נגועות" בכבילה במסגרת בורות. ואולם ככל שהדברים נוגעים למחלוקת סביב שאלת הפרתו של סעיף 17 – לא היה מקום למינוי בורר.

26. כאמור, החוזה שכרתו הצדדים בענייננו, שבו מופיעה תניית הבוררות נושא הליך זה, כולל לדעתי הסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים. הסדר כובל, ללא אישור, היתר זמני או פטור, הינו עבירה פלילית, מכוח סעיפים 4 ו-47(א)(1) לאותו החוק. על השאלה אם ניתן להפעיל את תניית הבוררות שבחוזה שחלקו מהווה עבירה פלילית, חולשים סעיף 3 לחוק הבוררות וסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים).

סעיף 30 לחוק החוזים, שכותרתו "חוזה פסול", עניינו תוקפו של חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור. סעיף זה קובע:

"חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל".

א

ואילו עניינו של סעיף 3 לחוק הבוררות הינו, תוקפו של הסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין צדדים. סעיף זה קובע:

"סייג להסכם 3. אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים".

ב

27. מסעיפים אלו אנו למדים, כי כדי שניתן יהיה להעביר עניין לבוררות לפי חוק הבוררות, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: ראשית, על הסכם הבוררות – כחוזה – להיות תקף, במובן זה, שהוא אינו פסול לפי סעיף 30 לחוק החוזים; שנית, על הסכם הבוררות להיות תקף, במובן זה שעניין הבוררות יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים.

ג

28. כאמור, אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. עניינים שאינם יכולים לשמש נושא להסכם בין צדדים כוללים, בין היתר: שיפוט משמעתי במסגרת התאגדות, בגין עבירות פליליות (הסמכות לשפוט בפלילים שמורה למדינה); בוררות בעניין מינהלי (אסור לרשות המוסמכת להתפרק משיקול-דעתה); בוררות לגבי משפט המגן בדיני העבודה (בורר אינו יכול לוותר בשם של עובד על זכויות שאסור לעובד עצמו לוותר עליהן) (אוטולנגי [57], בע' 54-55, 78-81); דברי השופט זמיר בבג"ץ 816/98 אמינוף נ' אלטלף (להלן – פרשת אמינוף [32]).

ד

29. עניין נוסף שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין צדדים, על-פי סעיף 3 לחוק הבוררות, הינו הסכם בלתי חוקי:

ה

"הפסיקה מלמדת כי בית-המשפט, בלי לדקדק בלשונו של סעיף 3 לחוק הבוררות, שולל תוקף... מהסכם בוררות שהוא בלתי חוקי... על הסכם כזה ניתן לומר כי הוא נתפס על-ידי סעיף 3 לחוק הבוררות, שכן הצדדים אינם יכולים לערוך... הסכם שהוא בלתי חוקי... על הסכם כזה ניתן לומר גם שהוא נתפס על-ידי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, הקובע כי חוזה שהוא בלתי חוקי... הינו בטל. אכן, בית-המשפט עדיין לא הבהיר את היחס בין סעיף 3 לחוק הבוררות לבין סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי). אך ברור שחוזה בלתי חוקי... כיוון שהוא בטל, אינו יכול לשמש בסיס לבוררות" (השופט זמיר בפרשת אמינוף [32], בעמ' 804-805).

ו

ז

30. אם כן, חוזה בלתי חוקי, במובן סעיף 30 לחוק החוזים, אינו יכול לשמש נושא להסכם בין צדדים, ועל-כן אינו יכול להיות העניין של בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות. כזכור, הגדרנו שני תנאים מצטברים להעברת עניין לבוררות, כאשר כל תנאי קשור לאחד משני סעיפי חוק אלו. אמנם, עינינו הרואות כי דיוננו בסעיף 3 לחוק הבוררות הוביל אותנו גם לסעיף 30 לחוק החוזים, אך אין לטשטש את הקטגוריות שבדיוננו. כדי שיהיה ניתן להעביר עניין לבוררות, הסכם הבוררות עצמו צריך להיות חוקי לפי סעיף 30 לחוק החוזים, ובנוסף, על-פי סעיף 3 לחוק הבוררות, מושא הבוררות צריך להיות עניין שניתן להעבירו לבוררות, כלומר מושא הבוררות, כמו הסכם הבוררות עצמו, אינו יכול להיות בלתי חוקי, לפי סעיף 30 לחוק החוזים.

31. האם הסכם הבוררות בענייננו תקף לפי סעיף 3 לחוק הבוררות? כלומר האם מושא הבוררות בענייננו יכול לשמש הסכם בין הצדדים? כאמור לדעתי, מושא הבוררות בענייננו הינו הסדר כובל ללא אישור או פטור, שהינו עבירה פלילית. המפיצים טוענים, לשיטתי, להפרת ההסדר הכובל ומבקשים להעביר את הדיון בשאלה אם ההסדר הופר, ובתרופות להפרה כאמור לבורר, אולם סעיף 3 לחוק הבוררות אוסר בוררות על סמך ההסדר הכובל, כי בהיותו חוזה בלתי חוקי אין הוא יכול לשמש הסכם בין הצדדים.

32. אמנם, הסדר כובל שקיבל אישור, אישור זמני או פטור לפי חוק ההגבלים העסקיים, אינו חוזה בלתי חוקי. חזקה על רישיון הנדרש על-פי דין, שלא אוזכר בחוזה – כמו האישור או פטור להסדר הכובל בענייננו – שהוא תנאי מתלה, ועל-כן ההסדר הכובל בענייננו אינו לכאורה חוזה בלתי חוקי כשלעצמו (סעיף 27 לחוק החוזים; אוטולנגי [57], בעמ' 57). אולם בענייננו פעלו הצדדים על בסיס ההסדר הכובל, ותוקפו כבר פג, עובדות המוכיחות שאין בענייננו תנאי מתלה הדוחה את ביצוע החוזה. החוזה בענייננו בוצע בפועל.

33. חברי מציין כי אף אם ההסדר הכובל הוא חוזה בלתי חוקי, ניתן להפריד בינו לבין תניות אחרות שבחוזה, לרבות תניית הבוררות. על דרך העיקרון, הדברים מקובלים עליי (ראה את דעת השופט ש' לוין ודעת השופטת נתניהו בע"א 65/85 הנ"ל (עניין עיריית נתניה [15])) הנזכר על-ידי חברי, אולם כאמור, עניינה העיקרי של הבוררות המתבקשת הינו ההסדר הכובל. כאמור – הסדר כובל זה אינו יכול להיות נושא להסכם בין צדדים, ועל-כן אינו יכול להידון בבוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות.

34. זאת ועוד, אף מפסק-הדין בעניין עיריית נתניה [15] אין ללמוד, לדעתי, שניתן לנהל בבוררות את התביעה, נושא ההליך שבפנינו, לפי הגישות השונות המובאות בו.

בעניין עיריית נתניה [15], מועצת עיריית נתניה הקימה חברה שהתקשרה עם יזם (הוא חברת נצ"ב), במקום שהעירייה תתקשר עם היזם בעצמה – כל זאת כדי להתחמק מקבלת אישור עבור העירייה משר הפנים, כנדרש בדין. כאשר החליטה עיריית נתניה להתנער מהחוזה, פעל היזם למינוי בורר על-פי החוזה בתביעה להשבה בלבד. בתגובה תבעה עיריית נתניה את היזם לסעד הצהרתי שיצהיר, בין היתר, כי החוזה בלתי חוקי, וכי אין אפשרות להעביר את הסכסוך להכרעה על-ידי בורר. השופט ד' לויין עמד על ההבחנה, לעניין תוצאות של אי-חוקיותו של חוזה, בין עתירה לאכיפת חוזה לבין עתירה להשבה בלבד. כן עמד הוא על השיקולים לפי סעיף 31 לחוק החוזים, לרבות השיקולים, שאם תובע מבקש לאכוף את החוזה כדי לממש את הכוונה הבלתי חוקית, וככל שאשמת התובע גדולה יותר, יסתייג יותר בית-המשפט מלהפעיל את סעיף 31. השופט ד' לויין עומד על היעדר האשמה של היזם שם [15] ועל העובדה שהוא איננו מבקש את אכיפת החוזה, אלא רק השבה. לאחר דברים אלה הוא מציין:

"כבר מהטעמים שפירטתי בהרחבה לעיל באשר לתוצאות המשפטיות הנובעות מאי-חוקיותו של החוזה, ייאמר, כי אותה אי-חוקיות אינה צריכה לשלול מחברת הפיתוח [היזם] ומהקשורים בה היזקקות להסכם הבוררות. הוא שריר וקיים לצורך ענייננו ועומד בפני עצמו" (שם [15], בעמ' 58).

קרי, לאור היעדר אשמת היזם והעובדה שהוא מבקש השבה בלבד, יש להחיל עליו את סעיף 31 לחוק החוזים, לעומת זאת בענייננו אין הצד המבקש לתבוע (בבוררות) מבקש השבה, אלא פיצויים.

35. לדידו של השופט ש' לויין, החוזה כלל אינו חוזה בלתי חוקי בטל דעיקרא, אלא חוזה על-תנאי לפי סעיף 27 לחוק החוזים, אשר נתבטל כאשר האישור הנדרש לא הושג תוך זמן סביר. על-כן ממילא לא הייתה רלוונטיות, לדידו, ל"החייאת" חוזה לפי סעיף 31 לחוק החוזים, שעניינו חוזה בטל דעיקרא. אף לדעתה של השופטת נתניהו, שם [15], שיקול-הדעת אם להחיות חוזה לפי סעיף 31 לחוק החוזים אינו רלוונטי, כי ממילא השבה לפי סעיף 21 לחוק החוזים היא תוצאה אוטומטית על-פי סעיף 31 לאותו חוק (אלא אם בית-המשפט יקבע אחרת).

36. לסיכום, רואה אני אפוא בענייננו קשר בל יינתק בין שתי הסוגיות: סוגיית ההסדר הכובל וסוגיית מינוי הבורר. אם תישמע דעתי נקבע שסעיף 17 להסכם, שהוא לב לבו של הסכסוך, הסדר כובל הוא, ולא נאשר את ההחלטה למנות בורר. עניינה של קאלמא מצוי כאמור ממילא בבית-המשפט במסגרת טענת קיזוז שהעלתה בתביעה

שהוגשה נגדה. צפי יכולה להגיש תביעה משל עצמה, ואם הדבר עדיין ניתן, יהיה אפשר לאחד את הדיון בתביעה זו עם תביעתה של אקסטל.

א

37. לעניין הוצאות משפט: אקסטל מתנערת מהסכם שחתמה עליו בטענה שהסדר כובל הוא. גם לשיטתי אין לזכותה בהוצאות.

ב

השופטת א' פרוקצ'יה

חבריי השופטים טירקל ונאור העמיקו חקור בשאלת קיומו של הסדר כובל מכוח הסכם בין הצדדים להליך זה, ונקטו עמדות שונות בסוגיה זו. בחינה זו נעשתה לצורך הכרעה בשאלה אם לקיים בוררות בין הצדדים לצורך בירור מחלוקת שנתגלעה במסגרת היחסים החוזיים ביניהם. בהקשר הדברים האמור אינני רואה צורך לנקוט עמדה משלי באשר לתפיסה המשפטית הראויה ביחס לפרשנות של הוראות חוק ההגבלים העסקיים, ולהשלכתו על ההסכם בין הצדדים. זאת מן הטעם כי לטעמי, בשלב זה של ההליך יש לקיים את הבוררות בין הצדדים בלא להידרש להכרעה בשאלות כבדות המשקל הכרוכות בסוגיית ההסדר הכובל. אלה עיקרי טעמי:

ד

(א) שיטת המשפט במקומנו מייחסת חשיבות רבה למוסד הבוררות כמערכת חלופית להכרעה שיפוטית בסכסוכים בין בעלי-דין. יתרונות הבוררות רבים הם הן מן ההיבט של הפרט הן מן ההיבט של הכלל. הבוררות מקדמת אינטרס ציבורי כללי ומשרתת אינטרס פרטי של בעלי-הדין ונותנת ביטוי לרצונם. היא מקלה את העומס בבתי-המשפט ומאפשרת הכרעה במחלוקות במסגרת שנבחרה על-ידי הצדדים, הכפופה לעקרונות בסיסיים הקבועים בדין, ונתונה לביקורת שיפוטית. המדיניות השיפוטית המושרשת מבקשת לקדם את מנגנון הבוררות המוסכמת בגבולות הדין ולמנוע את קיומה במקרים חריגים בלבד.

ה

ו

(ב) סעיף 3 לחוק הבוררות קובע כי אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. משמעות הוראה זו היא, בראש ובראשונה, כי אין הסכם בוררות יכול להתקיים מקום שהוא נוגע לעניין שמעצם טיבו אינו יכול להידון בבוררות כי אם בערכאות שיפוט בלבד. כך הם למשל הוראת בוררות המבקשת להביא שיפוט בעבירה פלילית למסגרת ארגונית פנימית (ע"א 11/56 "אגד" (ד.ש.א.) בע"מ נ' 991 [33]); עניינים שנמסרו לסמכות שיפוט ייחודית כגון ענייני מעמד אישי של נישואין וגירושין שעניינם קביעת סטטוס שכוחו יפה כלפי כולי עלמא, או סכסוך שהכרעה בו הינה בעלת משמעות חפצא הפועלת גם כלפי צדדים שלישיים (אוטולנגי

ז

א

בספרה הנ"ל [57], בעמ' 66-74). שנית, הוראה זו חלה על הסכמי בוררות בלתי חוקיים שאי-החוקיות ברורה וגלויה על פניהם, בבחינת "mala per se" (רע מעצם טיבו). כך הוא מקום ששאלת אי-החוקיות נהירה על פניה ואינה מחייבת בירור וליבון (אוטולוגי בספרה הנ"ל [57], בעמ' 56).

ב

שונה הדבר מקום שצד להסכם בוררות מעלה טענת אי-החוקיות המחייבת בירור ובחינה לצורך ביסוסה. פנים רבות לטענת אי-החוקיות: אי-החוקיות עשויה להתייחס לעצם ההסדר החוזי המפורש בין הצדדים ולחייב בירור מעמיק לגבי טיב ההסדר על רקע הוראות הדין. היא עשויה להתייחס לתכלית החוזה שאפשר שאינה באה לידי ביטוי מפורש בכתובים כלל, או לאי-החוקיות הנלווית לאופן ביצועו של ההסכם. ואמנם, חוזה עשוי להיחשב פסול בין מבחינת הליך כריתתו, בין מבחינת תוכנו ובין מבחינת מטרתו (סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי)). יתר-על-כן, עצם היות חוזה מנוגד לחוק אינו בהכרח קובע את היותו חוזה פסול. הדבר תלוי בפירוש החוק הנוגע בדבר על-פי תכליתו (ע"א 87/50 ליבמן נ' ליפשיץ [34]; שלו בספרה הנ"ל [56], בעמ' 359-360). אי-החוקיות עשויה להתייחס לשני הצדדים להסכם או לצד אחד בלבד, על-פי העניין. וכך, השאלות הכרוכות באי-החוקיות הסכמים עשויות להיות מורכבות וסבוכות ביותר. לצורך בירורן הן עשויות לחייב לא רק בחינה משפטית מקיפה של הדין, אלא גם בירור יסודי של הרקע להסכם, של מערכת היחסים בין הצדדים לו ושל מכלול עובדות שבלא קביעתן יקשה לנקוט עמדה בטענת אי-החוקיות. וכך, נכונות בית-המשפט להיענות לבקשת צד לבוררות לעכב את הליכי הבוררות לצורך בחינת טענת אי-החוקיות מקום שהיא אינה עולה על פניו של ההסכם, עלולה בנקל לסכל את יעדה המרכזי של הבוררות – לשמש מנגנון מוסכם יעיל ומהיר לפתרון מחלוקות בין צדדים. נכונות כזו עשויה לשמש אמצעי בידי צד שאינו מעוניין בבוררות להכשילה, או למצער לעכבה לצורך בירור טענות אי-החוקיות, גם אם הן עשויות להימצא בהמשך הדרך בלתי מבוססות. הדבר עלול לשמש פתח מילוט מן הבוררות לצד שאינו חפץ בה, אף שנתחייב לה בעבר.

ג

ד

ה

ו

ז

(ג) בחינת השיפוטית "לפני מעשה" של טענת אי-החוקיות של הבוררות מעלה אפוא קשיים רבים, ומקום שבירורה מחייב בדיקה מעמיקה – משפטית ועובדתית – חסרונותיה מאפילים על תועלתה. בנסיבות שבהן אין זה ברור על פניו כי מדובר בהסכם אשר מטיבו אינו יכול לשמש נושא להסכם בוררות בין צדדים, ראוי להתיר את קיומה של הבוררות ולהימנע מבחינה לגופן של טענות אי-החוקיות לפני מעשה. עם זאת בחינה לאחר מעשה תיעשה במסגרת הפיקוח השיפוטי על החלטות בורר. הכרעת הבורר, ככלל, כפופה לפיקוח שיפוטי של בית-המשפט, בין היתר במסגרת עילות ביטול הפסק. אחת מעילות הביטול מתקיימת מקום שתוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור

א (סעיף 24(9) לחוק הבוררות). במסגרת זו, ולאחר הכרעת הבורר, יש להביא בפני בית המשפט טענות אי-חוקיות אם הן עולות מנסיבות העניין, ובית-המשפט ידון בהן ויכריע בהן. באופן כזה יושג איזון ראוי שבו יימצא מוסד הבוררות מוגן מפני ניסיון למנוע את הפעלתו או להשהותה באמצעות טענות המחייבות לפרקים ניהול התדיינות שיפוטית נרחבת, יהיו אשר יהיו תוצאותיה של אותה התדיינות; מנגד יישמר פיקוח שיפוטי על תוכנו של פסק הבורר מן ההיבט של תקנת הציבור, החולש מעצם טיבו גם על עניינים שדבקה בהם אי-חוקיות. באמצעות כלי בקרה זה בכוחו של בית-המשפט למנוע את אישורו של פסק בורר שדבק בו פסול של אי-חוקיות.

ב (ד) החשש כי בחינה לאחר מעשה של טענת אי-חוקיות המצריכה בירור מורכב, תאפשר ניהול בוררות פסולות במחשכים תוך פגיעה באינטרס הציבורי, אינו כבד משקל בעיניי. מקום ששני הצדדים לבוררות מבקשים לדון בעניינם בחדרי חדרים ומחוץ לעינו הפקוחה של החוק, הם יעשו כן בכל מקרה, ויש להניח כי אף יבצעו את הכרעת הבורר בלא סיוען של רשויות אכיפת החוק. מנגד, מקום שצד אחד לבוררות יתנגד לקיומה ויבקש את סיועו של בית-המשפט לצורך כך, ממילא תיחשף הבוררות לעין המשפט, ומאותו שלב ואילך תועמד הבוררות למבחן ביקורת שיפוטי. בכללו של פיקוח זה גם בחינת תוקפו של פסק הבורר מן ההיבט של תקנת הציבור.

ג (ה) לאורך שנים הגנו בתי-המשפט על מוסד הבוררות, ככל הניתן, בפני טענות אי-חוקיות. הם חיפשו כל דרך להכשיר את הבוררות ולהימנע מפוסלה. הם ביקשו לתת תוקף, במידת האפשר, להסכמת הצדדים לבוררות ולמצות, ככל הניתן, את היתרונות הרבים הטמונים בה לפרט ולכלל. במסגרת זו קבעה הפסיקה כי גם מקום שנערך הסכם בלתי חוקי אין לפוסלו לצורך בוררות אם עדיין ניתן להכשירו, למשל על-ידי קבלת רישיון מקום שנדרש רישיון כזה, או כאשר ניתן להפריד, באמצעות עקרון "העפרון הכחול", בין חלקי החוקיים של ההסכם לחלקיו הבלתי חוקיים. כן נקבע כי הסכם עסקי בעל אופי כספי, אפילו הוא נגוע באי-חוקיות, עשוי להצמיח בידי בעל-דין עילות תביעה המנותקות מההסכם, למשל מתחום הקניין ועשיית עושר ולא במשפט, וניתן להכיר בתוקפה של בוררות העוסקת בעילות אלה (ע"א 65/85 הנ"ל [15], בעמ' 59; ע"א 108/60 זקס נ' מוסרי [35], בעמ' 2254; ע"א 344/83 רויטמן נ' פרס [36], בעמ' 34; ע"א 60/68 בנין, חברה לביטוח בע"מ נ' הרשקוביץ [37], בעמ' 627; המ' 230/58 כ"ץ נ' וולף [38]; ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד [39]).

ד (ו) יתרה מזו, גם חוזה בלתי חוקי בטל עשוי להצמיח תרופות במשפט. זאת מורה סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי). אין מקום להניח כי המחוקק ביקש לשלול מבורר מלכתחילה אפשרות להכריע בתביעה לתרופות שצד עשוי להיות זכאי להן גם מכוח

א

הסכם בטל מחמת אי-חוקיות, על-פי סמכות זהה לזו הנתונה בעניין זה לבית-המשפט (ע"א 335/78 הנ"ל [10]). המדיניות המשפטית הנוהגת מחזקת אפוא את הנטייה לקיים את הבוררות גם מקום שמועלית כנגדה טענת אי-חוקיות בידי צד המבקש שלא לקיימה, ולהימנע מבירור שיפוטי לגופה של הטענה מקום שהיא אינה מסתברת על פניה, והיא טענה מחקר ובחינה מעמיקים.

ב

(ז) מן הכלל אל הפרט

ג

ענייננו עוסק בטענת אי-חוקיות הנוגעת בסוגיית ההסדר הכובל שמעלה צד שאינו חפץ לקיים הסכם בוררות שהוא צד לו. העניין מעמיד לבחינה סעיף מפורש בהסכם, ומתבקשת הכרעה שיפוטית אם מדובר בהסדר כובל בלתי חוקי בין הצדדים. במקרה זה אין מדובר באי-חוקיות הבוררה על פניה. סוגיית ההסדר הכובל היא אחת הסוגיות הקשות והסבוכות במשפט. בירורה טעון לא רק פרשנות משפטית עיונית. בשל ההיבטים הכלכליים-עסקיים רבי הממדים הקשורים בה בחינתה מחייבת לא אחת גם היזקקות למומחים ולתשתית ראייתית-מקצועית נרחבת. הדבר עשוי לחייב גם בירור עובדתי קונקרטי הקשור במערכת היחסים בין הצדדים. מתחייבת בחינה מורכבת ומעמיקה. מדובר בסוג טענות אשר לצורך הכרעה בהן – ולו לצורך בירור שאלת תקפותו של סעיף הבוררות – יש לערוך דיון שיפוטי, אשר הוא גופו, ואף בלא קשר הכרחי לתוצאתו הסופית, עשוי להכשיל את הבוררות או לעכבה בשל משאבי הזמן הנדרשים לניהולו. גם אם תימצא טענת אי-החוקיות בסופו של דבר טענת סרק, יבוא הצד המתנגד לבוררות על סיפוקו בהשעיית ההליך המוסכם על הצדדים, לעתים למשך שנים, עד למיצוי הליכים בשאלה האינצידנטלית אם ניתן לקיים את הבוררות.

ה

(ח) זאת ועוד, בירורה של סוגיית ההסדר הכובל לצורך הליך בוררות הופכת שאלה שהיא אינצידנטלית באופייה לשאלה עיקרית, ואילו העניין העיקרי – אם לקיים בוררות אם לאו – הופך לשאלה אגבית. היפוך היוצרות הדיוני הזה אינו בריא, והוא עלול להביא לניהול משפט כולל בסוגיית ההסדר הכובל תוך ריקונו של נושא הבוררות מערכו הממשי, או לחלופין, לניהול הליך מקוצר בעניין ההסדר הכובל תוך סיכון הכרוך בקביעת מסקנות שיפוטיות בסוגיה מורכבת זו בלא שהונחה בפני בית-המשפט פריסה כוללת של כל היבטי העניין. גם בכך עלולה להימצא מכשלה. אף לא אחת משתי דרכים אפשריות אלה רצויה.

ו

ז

(ט) ולבסוף, טענת אי-החוקיות הכרוכה בהסדר כובל איננה מסוג טענות אי-החוקיות שהן בבחינת "רע מעצם טיבו". גם כשנמצא הסדר כובל בלתי חוקי, נתון הוא, בתנאים מסוימים, להכשר על-פי החוק. מדובר בעניין העשוי, חרף אי-החוקיות, להוליד

עילות תביעה מתחומי משפט שונים העשויות להצמיח זכויות למי מן הצדדים. ההסדר הכובל עשוי אף להוליד זכות לתרופות העומדות לרשותו של צד להסכם פסול על-פי סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי).

א

(י) ממכלול טעמים אלה היה ראוי בעניין זה שלא להיזקק לשאלת קיומו של הסדר כובל לגופה, כי אם להפנות את הצדדים לבירור עניינם בפני בורר כפי שהוסכם ביניהם לעשות. ואכן, השתלשלות הדברים מוכיחה כי הדרך שננקטה לבירור מקדמי של טענת אי-החוקיות זרועה מכשולים: בית-המשפט המחוזי קבע קביעה פסקנית כי אין מדובר בהסכם כובל על דרך ניתוח קצר דרך שמסקנה בצדו. חבריי בערעור בחנו, כל אחד מנקודת ראותו, את סוגיית ההסדר הכובל במחקר רב-עומק והגיעו למסקנות מנוגדות. תשתית עובדתית ומקצועית-כלכלית לטענת ההסדר הכובל בהליך זה לא הונחה על-ידי הצדדים, מאחר שמרכזו של הדיון לא יועד כלל לבחינת סוגיה זו.

ג

ובינתיים, בוררות שהייתה אמורה להתנהל כבר בשנת 2000, ממתינה בפתח להכרעת בתי-המשפט, על ערכאותיהם, ויתרונו הדיוני של הליך הבוררות נפגע.

ד

(יא) אני מצטרפת אפוא למסקנת חברי השופט טירקל כי הבורר מוסמך לדון במחלוקת בין בעלי-הדין, וזאת לטעמי, אף בלא הכרעה בשאלה אם לפנינו הסדר כובל. למותר לומר כי הכרעת הבורר כפופה לביקורת שיפוטית, על כל המשתמע מכך.

ה

אוסף עוד כי העובדה כי מתנהל הליך נוסף בין הצדדים בבית-המשפט ביחס לתקופה שלאחר ההסכם ביניהם, וכי המשיבה 1 טוענת טענת קיזוז במסגרתו, אינה בגדר עילה מספקת לסטות מסעיף הבוררות בהסכם ולהורות על אי-קיום הבוררות ועל הפניית הצדדים להליך בבית-המשפט ביחס לתקופת ההסכם.

ו

לפיכך הוחלט ברוב דעות, נגד דעתה החולקת של השופטת נאור, לפי תוצאת פסק-דינו של השופט טירקל.

ניתן היום, י"ב בשבט תשס"ד (4.2.2004).

ז

מיני-רציו:

- א * בוררות – הסכם בוררות – תוקפו
תניית בוררות בחוזה – האם תקפה כאשר נטען שהחוזה עצמו אינו חוקי.
* הגבלים עסקיים – הסדר כובל – מהו
האם יש להבחין בין הסדר כובל אופקי להסדר כובל אנכי – חלוקת שוק.
ב * חוזים – אי-חוקיות – הסדר כובל
טענה לאי-חוקיות הסכם בהיותו הסדר כובל – האם יש להבחין בין הסדר כובל אנכי
להסדר כובל אופקי – האם יש לברר תניית בוררות בהסכם שננטען לגביו שהוא הסדר
כובל.
ג

ד

ה

ו

ז